

제30장

소송의 종료

제1절	총 설	292
제2절	판결의 성립과 선고 및 확정	304
제3절	소의 취하	323
제4절	소송상 화해	332
제5절	청구의 포기와 인낙	352
제6절	기타 사유에 의한 소송의 종료	358

제1절 총 설

1. 서 설

가. 소송종료사유

민사소송법이 규정하는 원칙적인 소송종료사유는 종국판결이지만(민소 198조), 예외적으로 재판장의 소장각하명령(254조 2항)에 의하여 종료되기도 하고, 조정을 갈음하는 결정, 화해권고결정, 이행권고결정 등에 의하여 종료되기도 한다. 또한 소의 취하 또는 취하간주, 소송상 화해, 조정, 청구의 포기·인낙 등과 같이 당사자의 행위에 의하여 종료되기도 한다.

이 밖에도 소송계속 중 대립당사자 구조가 소멸됨으로써 소송이 종료하는 경우가 있다. 원·피고의 지위가 혼동된 경우(예컨대 원고가 사망하고 피고가 원고의 단독 상속인으로서 소송물인 상속재산을 상속한 경우 또는 대립당사자인 두 법인의 합병 등)라든가, 소송물인 권리관계의 일신전속적 성질상 승계가 허용되지 않는 소송에서 당사자가 사망한 경우[예컨대 이사가 그 지위에 기하여 주주총회 결의 취소의 소를 제기하였다가 소송계속 중에 사망하였거나 사실심 변론종결 후에 사망한 경우(대법원 2019. 2. 14. 선고 2015다255258 판결)]가 그것이다.

나. 소송종료선언

소송종료선언이라 함은 계속 중인 소송이 유효하게 종료되었음을 확인하는 것으로서, 이는 종국판결로 소송판결에 해당하며 상소가 허용된다.

소송종료선언의 사유는 다음 세 가지이다.

첫째, 당사자가 소송이 종료되었다는 것을 다투면서 기일지정신청을 하는 경우이다. 소 또는 상소의 취하(취하간주 포함)의 효력에 관한 다툼이 있어 당사자가 기일지정신청을 하는 경우, 법원은 기일을 열어 신청사유를 심리하고, 신청이 이유 없으면 소송종료선언을 한다(민소규 67조, 68조, 135조, 136조).

청구의 포기·인낙, 소송상 화해, 조정의 효력에 관하여 다툼이 있어 당사자가 기일지정신청을 하는 경우에도 같다. 자세한 내용은 제19장(기일과 기간) 제7절 참조.

둘째, 확정판결, 소의 취하 또는 취하간주, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해 등에 의하여 소송이 종료되었음에도 불구하고 이를 간과하고 심리를 계속 진행한 사실이 발견된 경우, 법원은 직권으로 소송종료선언을 하여야 한다. 특히 상소심법원은 당사자의 이의 여부에 관계 없이 직권으로 이러한 사유가 있는지를 조사하고, 이를 발견하면 그 부분의 판결을 파기하고 소송종료선언을 하여야 한다(대법원 1991. 5. 24. 선고 90다18036 판결). 원고가 민사소송법 70조에서 정한 예비적 공동소송의 형태로 청구하였으나 공동소송인들에 대한 청구가 법률상 양립할 수 없는 관계가 아닌 경우 이는 통상 공동소송에 해당하고, 그 판결에 대하여 공동소송인 중 일부에 대해서만 불복할 경우에는 그 부분만 항소심으로 이심되고 항소심의 심판대상이 되는데, 항소심이 불복하지 않은 피고 부분도 항소심으로 이심된 것으로 잘못 보고 판단한 경우 상고심은 그 부분을 파기하고 소송종료선언을 하여야 한다(대법원 2012. 9. 27. 선고 2011다76747 판결).

셋째, 앞에서 본 바와 같이 소송계속 중 대립당사자 구조가 소멸되는 경우에 법원은 항상 소송종료선언을 하여야 한다는 견해도 있으나, 이 경우 바로 소송은 종료된다고 봄이 실무이다. 법원사무관등은 공용부전지 또는 별도로 생성한 문서에 “20〇〇. 〇. 〇. 원고의 사망으로 인하여 종료”와 같이 기재하고 재판장의 확인을 받은 후 민사종국코드에 “기타”로 입력하면 된다. 참고로 종이기록사건의 경우 기록표지 다음 장의 ‘기일지정’란에 “20〇〇. 〇. 〇. 원고의 사망으로 인하여 종료”와 같이 기재한 후 재판장의 인인(認印)을 받고 민사종국코드에 “기타”로 입력하면 된다. 다만 소송이 종료되었는지 여부에 대하여 다툼이 있어 기일지정을 신청한 경우 등에는 법원은 판결로써 소송종료선언을 하는 것이 타당하다(대법원 1992. 5. 26. 선고 90므1135 판결).

다. 민사종국코드의 입력

소송이 종료되면 법원사무관등은 그 사유에 따라 바로 재판사무시스템상 민사종국코드를 입력하여야 한다.

코드값	종국코드명	코드값	종국코드명
29	각하명령	67	파기자판(각하)
30	신청취하	68	항소각하
31	취하간주	69	신청각하
32	소취하	71	재정합의
33	소장각하명령	72	재정단독
34	항소장각하	73	항소기각
35	항소취하	74	심리불속행기각
36	항소취하간주	76	상고이유서부제출기각
37	상고장각하	77	파기환송
38	상고취하	78	파기환송(일부)
39	신청서각하	79	파기이송
41	화해	80	각하판결
42	포기	81	지급명령이의신청취하
43	인낙	84	상고기각
44	이송	85	조정이의신청각하
45	재심청구기각	86	화해권고결정이의신청취하
46	화해권고결정	87	화해권고결정이의신청각하
52	조정성립	88	강제조정결정취소
53	강제조정	89	강제조정이의
54	조정불성립	90	이행권고결정
55	조정하지아니하는결정	109	재배당
56	조정신청취하간주	204	취하
58	파기자판(원고승)	221	각하결정
59	파기자판(원고일부승)	318	조정이의신청취하
60	파기자판(원고패)	319	탈퇴
61	원고승	321	소취하(판결후)
62	원고일부승	322	배당전종국
63	원고패	803	독립당사자참가인승
64	소각하	804	소송불하기결정확정
65	소송종료선언	991	사건부 참조
66	판결기타	992	정보화 2413-30호에 의하여 종결처리함
		999	기타

2. 재 판

가. 재판의 의의

재판이라 함은 사건에 관하여 법령을 적용하여 행하는 법원 또는 법관의 판단 내지 의사표시로서, 그에 의하여 소송법상 일정한 효과가 발생하는 소송행위를 말한다. 법원 또는 법관의 행위이기 때문에 법원사무관등이나 집행관의 행위와 구별되며, 의사표시적 소송행위이기 때문에 사실상 행위인 증거조사나 변론의 청취 등과도 구별된다.

나. 재판의 종류

(1) 서 설

재판을 하는 주체와 성립절차에 따라 판결·결정·명령의 세 가지로 구분하는 것이 재판의 대표적인 분류이다.

재판의 주체 면에서 볼 때 판결과 결정은 법원(합의부인 때에는 그 합의부)이 행하는 재판이고, 명령은 개개 법관(재판장·수명법관·수탁판사)이 행하는 재판이다. 단독판사의 경우에는 그 단독판사가 법원 겸 재판장의 지위를 가지는데, 이 경우에는 합의부의 경우에 준하여 재판의 종류를 정하게 되나, 재판서나 소송서류에서의 호칭은 언제나 ‘판사’이며 ‘재판장’이라는 호칭은 사용하지 않는다.

다만 수명법관·수탁판사의 직무집행에 관하여 법원의 직무를 행할 수 있도록 되어 있는 경우(민소 332조, 333조, 373조)에는 수명법관·수탁판사도 결정을 할 수 있는 경우가 있다.

한편 재판의 성립절차 면에서 볼 때 판결은 결정·명령과 구별된다. 즉 판결은 나머지 두 재판에 대하여 큰 차이를 보이는데, 그 구체적 내용은 종류별로 따로 설명한다.

(2) 판 결

판결이란 소송절차의 중요사항(소의 적법 여부, 청구의 인용 여부 등)에 관한

중국적 또는 중간적 판단을 내용으로 하며, 법률이 따로 정한 경우를 제외하고는 반드시 변론을 거친 다음(민소 134조 1항 본문), 일정한 형식을 갖추고 법관이 서명날인한 판결원본을 작성하여(206조, 208조) 선고기일에 법정에서 선고함으로써 효력이 생긴다(205조, 207조). 이에 대한 불복은 항소, 상고에 의하여야 한다.

다만 예외적으로 ① 피고가 민사소송법 256조 1항의 답변서를 제출하지 아니하는 경우(민소 257조 1항), ② 부적법한 소 또는 상소로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우(219조, 413조, 425조), ③ 상고심에서 소송기록에 의하여 판결할 수 있는 경우(430조 1항), ④ 소액사건에서 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 분명한 경우(소액 9조 1항), ⑤ 원고가 소송비용에 대한 담보제공을 이행하지 아니하여 소각하판결을 하는 경우(민소 124조)에는 변론 없이 판결을 선고할 수 있다. 나아가, 상고인이 상고이유서를 제출하지 아니한 경우(429조)에 하는 상고기각의 판결과 상고이유에 관한 주장이 상고심절차에 관한 특례법 4조 소정의 사유를 포함하지 아니한다고 인정하는 경우에 하는 심리불속행 상고기각의 판결은 변론 및 선고를 요하지 아니하고 상고인에게 송달함으로써 그 효력이 생긴다(상고심특례 5조). 항소인이 항소이유서를 제출하지 아니할 때에는 항소법원이 결정으로 항소를 각하하여야 하는 점과 구분된다(민소 402조의3).

(가) 중국판결

중국판결이란 소 또는 상소에 의하여 계속된 사건의 전부 또는 일부를 그 심급에서 완결하는 판결이다.

① 본안판결과 소송판결

법원은 소송의 심리를 마친 때에는 중국판결을 한다. 원고의 청구를 인용하거나 기각하는 본안판결은 소송요건이 구비되어 있는 경우에 한하여 허용된다.

소송판결은 소 또는 상소를 부적법하다고 하여 각하하는 판결로서, 소송

요건 또는 상소요건의 흠이 있는 경우에 행하는 판결이다. 소송요건 또는 상소요건의 흠이 있을 때, 법원은 그 흠이 보정될 수 있는 것이면 보정을 명하고, 당사자가 보정하지 아니하는 경우 또는 처음부터 그 흠을 보정할 수 없는 때에는 소 또는 상소가 부적법하므로 이를 각하하는 소송판결을 하여야 한다(민소 219조, 413조, 425조).

소송요건이 구비되어 있는 경우에, 원고의 청구가 전부 정당한 때에는 청구의 전부인용판결을 하고, 원고의 청구가 일부만 정당한 때에는 청구의 일부인용(및 나머지 청구기각)판결을 하며, 원고의 청구가 전부 부당한 때에는 청구의 전부기각판결을 한다.

② 전부판결과 일부판결

소송의 목적으로 되어 있는 청구의 전부에 대하여 행하는 판결을 전부판결이라 하고, 청구의 일부에 대하여 행하는 판결을 일부판결(민소 200조)이라 한다.

원고가 여러 개의 청구를 병합하여 한 개의 소를 제기한 경우(소의 객관적 병합 또는 공동소송), 피고가 반소를 제기한 경우(민소 269조), 법원이 변론을 병합한 경우(141조) 등 여러 개의 소 또는 청구가 동일한 소송절차 내에서 심리되어 그 전부를 판결할 정도로 심리가 진행되었을 때에는 전부판결을 하여야 한다. 전부판결은 1개의 판결이므로 공동소송의 경우를 제외하고는 청구 중 일부에 대한 상소는 나머지 청구에 효력이 미치고, 판결 전체의 확정을 막는 차단의 효과와 위 심급으로 이전되는 이심의 효과가 생긴다.

한편 법원은 소송의 일부에 대한 심리를 마친 경우 그 일부에 대한 중급판결을 할 수 있다(민소 200조 1항). 특히 변론을 병합한 여러 개의 소송 중 한 개의 심리를 마친 경우와 본소나 반소의 심리를 마친 경우에도 그 마친 부분에 대하여 일부판결을 할 수 있다(2항).

다만 일부판결을 한 뒤 나머지 부분에 대하여 후에 선고하는 잔부판결(殘部判決)이 법률상 허용될 수 없는 경우나 일부판결과 잔부판결 사이에 내용

상 모순이 생길 염려가 있는 경우에는 일부판결이 허용될 수 없다. 즉 ① 선택적 병합청구(대법원 1998. 7. 24. 선고 96다99 판결)나 예비적 병합청구(대법원 2000. 11. 16. 선고 98다22253 전원합의체 판결)의 경우, ② 본소와 반소가 동일 목적의 형성청구인 경우(예컨대 공유물분할청구 등)나 그 소송물이 동일한 법률관계일 경우(예컨대 동일채권의 부존재확인)의 본소와 이행청구의 반소 등), ③ 필수적 공동소송과 독립당사자참가소송(대법원 1981. 12. 8. 선고 80다577 판결)의 경우, ④ 예비적·선택적 공동소송의 경우(대법원 2011. 2. 24. 선고 2009다43355 판결), ⑤ 법률상 병합이 요구되는 경우(상법 188조, 240조, 380조, 채무자회생 171조 5항, 174조 3항, 증집 14조 1항, 소비자단체소송규칙 15조)에는 일부판결을 하지 못한다.

이상의 경우를 제외하고는 일부판결을 할 것인가의 여부가 법원의 재량에 맡겨져 있고, 일부판결을 적절히 활용하면 소송의 정리·집중에 도움을 줄 수 있으며, 또 당사자의 권리구제의 신속에 이바지할 수 있다. 다만 일부판결은 독립하여 상소의 대상이 되기 때문에, 사건의 일부는 상소심에, 나머지 부분은 원심에 계속되게 되어서 때로는 소송불경제와 재판의 모순을 초래할 수도 있다.

일부판결을 하고자 할 때에는 그 부분의 변론을 분리하는 결정(민소 141조)을 먼저 하여야 한다. 일부판결 판결서의 판결표시에는 사건명 바로 뒤에 “(일부판결)”이라 기재한다. 일부판결 후 나머지 부분의 전체에 대한 잔부판결은 성질상 일부판결이지만 전체 사건이 종결되었음을 알 수 있도록 판결표시에는 단순히 “판결”이라고 기재한다. 한편 일부판결 후 나머지 부분에 대한 판결에 대하여는 원래의 사건번호에 가지번호를 붙여(예컨대 2025가합 100-1) 일부판결이 있었음을 명확히 하여야 한다(재판서예규 4조 5항, 7조 2항). 일부판결의 대상이 된 부분에 관한 비용을 다른 것과 구별할 수 있을 때에는 일부판결 중에서 따로 소송비용의 재판을 할 수 있다(민소 104조 단서). 특히 통상공동소송인들 중 한 사람과의 관계에서 먼저 판결을 할 때에는 소

송비용에 관하여도 동시에 재판할 하는 것이 간명하다.

③ 판결의 누락에 따른 추가판결

‘판결의 누락’은 법원이 청구의 전부에 대하여 재판할 의사로 판결을 하였지만, 객관적으로는 청구의 일부에 대하여 판결을 누락한 것을 말하고, 이러한 판결의 누락이 있는 경우에 법원이 그 부분에 대하여 행하는 종국판결을 추가판결이라 한다(민소 212조). 청구를 기각하는 판결의 경우에 청구 전부에 대한 판단이 기재되어 있는지 여부는 청구취지와 판결이유의 기재를 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 5. 30. 선고 2003다13604 판결). 앞에서 본 일부판결이나 잔부판결은 법원이 그 의사에 따라 판결을 나누어서 행하는 것이므로 판결의 누락이나 추가판결과 구별된다. 또 판결의 누락은 종국판결의 주문에서 판단할 사항(즉 청구 자체)에 관하여 생기는 것이므로 이유에서 실시할 사항(공격방어방법)에 대한 판단누락(451조 1항 9호)과도 다르다. 따라서 판결의 주문에 아무런 표시가 없는 이상 비록 이유에서 실시가 되어 있더라도 판결의 누락으로 보아 추가판결의 대상이 되고, 반대로 판결이유에는 아무 표시가 없더라도 판결주문에 기재가 있으면 이유를 붙이지 아니한 위법이 있기는 하나 판결의 누락으로 볼 수 없다(대법원 2002. 5. 14. 선고 2001다73572 판결).

한편 앞에서 본 일부판결이 허용되지 않는 소송에서는 판결의 누락이 있을 수 없으므로 추가판결로 시정할 것이 아니라(대법원 2008. 4. 10. 선고 2007다36308 판결), 빠뜨린 것이 있다면 판단누락의 일종으로 보아서 상소 또는 재심으로 다투어야 한다. 즉 제1심법원이 원고의 선택적 청구 중 하나만을 판단하여 기각하고 나머지 청구에 대하여는 판단하지 않은 판결을 한 경우 또는 제1심법원이 원고의 주위적 청구를 배척하면서 예비적 청구에 대하여는 판단을 하지 아니한 판결을 한 경우, 이 판결에 대하여 상소가 제기 되면 원고의 청구 전부가 상소심으로 이심되므로, 선택적 청구 중 판단되지 않은 청구 부분 또는 예비적 청구 부분이 판결의 누락으로서 원심에 계속되

어 있다고 볼 것은 아니다(선택적 청구에 관하여는 대법원 1998. 7. 24. 선고 96다99 판결, 예비적 청구에 관하여는 대법원 2000. 11. 16. 선고 98다22253 전원합의체 판결). 이 경우 당사자가 판단이 누락된 부분에 대하여 별도로써 청구하는 것은 권리보호의 이익이 없어 부적법하며(대법원 2002. 9. 4. 선고 98다17145 판결), 다만 당사자가 상고하여 판단누락 사유를 지적하였음에도 상고심에서 그 잘못이 시정되지 않은 채 판결이 확정되었다면 재심사유가 된다(위 98다17145 판결, 민소 451조 1항 9호). 다만 논리적으로 전혀 관계가 없어 순수하게 단순병합으로 구하여야 할 수개의 청구를 선택적 청구로 병합하여 청구하는 것은 부적법하여 허용되지 않는데도 원고가 그와 같이 병합하여 청구한 경우, 제1심법원이 그중 하나의 청구에 대하여만 심리·판단하여 이를 인용하고 나머지 청구에 대한 심리·판단을 모두 생략하는 내용의 판결을 하였다고 하더라도, 그로 인하여 청구의 병합 형태가 적법한 선택적 병합 관계로 바뀔 수는 없으므로, 이러한 판결에 대하여 피고만이 항소한 경우 제1심법원이 심리·판단하여 인용한 청구만이 항소심으로 이심될 뿐, 나머지 심리·판단하지 않은 청구는 여전히 제1심에 남아 있게 된다(대법원 2008. 12. 11. 선고 2006다5550 판결). 또한 당사자가 예비적 공동소송의 형태로 청구하고 있지만, 그 공동소송인들에 대한 청구가 상호 간에 법률상 양립할 수 없는 관계에 있지 않다면 이는 민사소송법 70조 1항이 규정한 예비적 공동소송은 아니고 그 청구의 본래 성질에 따라 통상 공동소송 등의 관계에 있다고 보아야 할 것이므로, 그러한 공동소송 관계의 판결에 대하여 공동소송인 중 일부에 대해서만 불복한 경우에는 그 부분만 상소심으로 이심이 되고 상소심의 심판권한의 범위도 당연히 그 부분에 한정된다(대법원 2012. 9. 27. 선고 2011다76747 판결).

판결이 누락된 부분은 계속하여 그 법원에 계속되어 있는 것이므로(민소 212조 1항) 그 법원이 추가판결을 하여야 하고, 당사자가 상소를 제기하여 시정을 구하는 경우에는 상소의 대상이 아니므로 부적법한 상소가 된다(대법

원 1996. 2. 9. 선고 94다50274 판결).

추가판결은 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 하는 것으로 해석된다. 추가판결에는 판결서의 판결표시에 “추가판결”이라고 기재하고 원래의 사건번호에 가지번호를 붙인다(재판서예규 4조 5항, 7조 2항). 추가판결을 구하는 당사자의 신청서가 제출되면 소송기록이 법원에 있을 때는 관계문서를 그 기록에 가철하여야 하고, 만약 상소 등에 의하여 소송기록이 법원에 없을 때에는 별도의 기록을 조제하지 않은 채 신속히 처리(추가판결의 선고, 송달, 상소장의 접수 등)를 한 후 관계문서 전부를 추송(追送)의 형식으로 소송기록이 있는 법원에 송부하여야 한다. 이때의 추송은 그 추가판결에 대하여 상소가 제기된 경우이건 아니건 언제나 하여야 하며, 소송기록송부서[전산양식 A2222]를 이용하되 ‘송부사유’란에는 “추가판결에 대한 원고의 항소”(항소가 제기된 경우) 또는 “추가판결의 확정”(항소가 제기되지 아니하여 확정된 경우) 등으로 구분하여 표시하여야 한다. 추송받은 법원에서는 그 문서를 그대로 본래의 소송기록에 가철하되, 항소가 제기된 경우에는 소정의 항소기록 접수절차를 밟아야 한다.

만약 추가판결을 할 사유인지 여부를 판단하거나 추가판결을 하기 위하여 원래의 소송기록이 필요한데, 이미 상소되어 기록이 상소법원으로 송부된 경우에는 상소법원에 기록송부촉탁을 하여 기록을 송부받아서 처리한 후 관계서류를 가철하여 반환하여야 한다. 추가판결을 할 사유에 해당하지 않아 이를 하지 않았거나 추가판결이 확정된 때 등에는 문서반환서[전산양식 A1704]만 첨부하면 되나, 추가판결에 대한 상소가 제기되었을 때에는 소송기록송부서[전산양식 A2223 또는 A2224]도 첨부해야 한다.

한편 중국판결 중 본래 하여야 할 소송비용의 판결을 누락한 때에는 결정으로 추가재판을 할 것이나(민소 212조 2항, 114조), 중국판결에 대하여 적법한 항소가 있는 때에는 그 결정은 효력을 잃고 항소법원이 소송의 총비용에 대하여 재판한다(212조 3항).

(나) 중간판결

중간판결이라 함은 중국판결 전에 독립된 공격 또는 방어방법, 그 밖의 중간의 다툼에 대하여 필요한 경우나, 청구의 원인과 액수에 다툼이 있는 경우에 그 원인에 대하여 하는 재판으로서 중국판결의 전제로 되는 판결이다(민소 201조). 그 밖의 중간의 다툼이라 함은 독립된 공격방어방법에 속하지 않는 소송상의 사항에 관한 다툼으로서 이를 해결하지 않으면 청구 자체에 대한 판단에 들어설 수 없는 것을 말하며, 소송상의 선결문제라고 한다. 예를 들면 소송요건의 존부, 상소의 적법 여부, 소취하의 유·무효, 상소 추후보완의 적법 여부, 재심의 소에서 적법성 여부와 재심사유의 존부(454조 참조) 등에 관한 다툼에서 요건이 인정되는 경우이다. 중간확인의 소(264조)에 대한 판결인 중간확인판결(중국판결로써 하게 된다)은 여기서 설명하는 중간판결이 아니다.

중간판결을 함에 있어서는 그 쟁점에 관하여 변론을 제한(민소 141조)하여야 할 것이고, 판결을 선고할 때에는 일반 원칙에 따라 판결서를 작성하여야 하며 그 정본을 당사자에게 송달하여야 한다. 중간판결은 소송물 자체에 대하여 중국적인 판결을 하는 것이 아니므로 이에 대하여는 독립한 상소가 허용되지 않고(390조), 중국판결에 대한 상소가 제기된 경우에 상소심에서 함께 판단을 받을 수 있을 뿐이다(392조).

중간판결을 할 것인지는 원칙적으로 법원의 재량이나(민소 454조 2항의 경우에는 예외임), 일단 선고하면 판결을 한 법원은 이에 구속되어 스스로 취소·변경할 수 없고, 나중에 중국판결을 할 때에 중간판결 주문에 표시된 판단을 전제로 하여야 한다. 설령 중간판결의 판단이 그릇된 것이라 하더라도 중국판결 시 중간판결에 저촉되는 판단을 할 수 없다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결).

중간판결에서는 소송비용의 재판을 하지 아니한다(민소 104조). 상소심에서 원심판결을 취소하여 환송하는 판결에 관하여 판례는 사건을 중국적으로

완결시키지는 않지만 당해 심급을 이탈시키는 판결인 점에서 종국판결설을 취하고 있다(항소심의 환송판결에 대하여는 대법원 1981. 9. 8. 선고 80다3271 전원합의체 판결, 상고심의 환송판결에 대하여는 대법원 1995. 2. 14. 선고 93재다 27 전원합의체 판결). 따라서 항소심의 환송판결(418조)에 대하여도 바로 상고할 수 있다.

(3) 결 정

법원이 주체가 되어 재판하여야 할 사항 중에서, 판결로 재판할 사항 이외의 사항에 관한 재판(소송절차 중 비교적 경미하고 신속을 요하는 사항에 관한 재판 또는 소송절차 아닌 절차에 관한 재판)은 결정으로 한다.

결정은 판결보다 그 절차가 간단하여 변론을 거칠지 여부는 법원의 재량에 맡겨져 있으며(민소 134조 1항 단서), 변론을 거치지 아니하고 서면심리만으로 또는 서면심리와 심문을 거친 후(2항) 상당한 방법으로 재판 내용을 고지함으로써 그 효력이 생긴다(221조 1항). 결정·명령의 원본이 법원사무관등에게 교부되어 성립한 경우, 결정·명령이 당사자에게 고지되어 효력이 발생하기 전에도 결정·명령에 불복하여 항고할 수 있다(대법원 2014. 10. 8. 자 2014마667 전원합의체 결정). 결정서를 작성하는 경우에는 판결서에 관한 규정이 준용되나, 판결서와는 달리 법관의 서명을 기명으로 갈음할 수 있고, 이유를 적는 것을 생략할 수 있다(224조 1항).

결정은 결정원본의 작성이 필수적이지 않고 조서에 기재하여 행하는 것이 가능하며(민소 154조 5호), 특히 변론 중에 행하는 소송지휘에 관한 결정은 조서에 그 재판의 내용과 이를 고지하였다는 것을 기재함으로써 행하는 것이 일반적이다. ① 변론의 제한·분리·병합 등 결정(141조), ② 조사촉탁 결정(294조), ③ 문서제출을 명하는 결정(347조), ④ 증거채택 여부 결정(290조), ⑤ 실기한 공격·방어방법 각하결정(149조) 등이 그 예이다.

(4) 명 령

법원 외의 재판기관 즉 재판장·수명법관·수탁판사가 행하는 재판은 명령

으로써 한다.

명령의 절차와 고지방법은 대체로 결정의 그것과 같다. 명령에 대한 불복은 항고·재항고·특별항고임이 원칙이나, 특별한 규정이 있는 경우도 있다(민소 138조에 따른 합의부에 대한 이의 등).

제2절 판결의 성립과 선고 및 확정

1. 서 설

판결의 성립절차는 먼저 법원이 어떤 내용의 판결을 할 것인지를 확정하고, 그 내용을 표시한 판결서를 작성한 후 이에 기하여 선고하는 순서대로 진행된다. 판결은 선고로 대외적으로 성립되고 효력이 생기며, 상소기간의 진행(민소 396조, 425조) 또는 강제집행개시의 요건(민집 39조 1항)으로서 판결의 정본을 당사자에게 송달한다.

2. 판결내용의 확정

가. 판결내용을 확정하는 법관

법원은 심리가 판결하기에 성숙된 때에는 변론을 종결하고 판결내용의 확정에 들어간다. 판결의 내용은 직접심리주의의 요청에 따라 ‘기본이 되는 변론에 관여한 법관’이 확정하여야 한다(민소 204조 1항). 변론종결 뒤 판결내용이 정해지지 않은 상태에서 법관이 바뀌면 변론을 재개(142조)하여 당사자에게 종전의 변론결과를 진술시키고 판결하여야 한다(204조 2항). 판결내용이 확정된 후에는 관여법관의 사망·퇴임·질병·출장 등에 의하여 판결서에 서명날인할 수 없더라도 합의부의 다른 법관이 판결에 그 사유를 적고 서명날인하면 되므로(208조 4항), 판결의 성립에는 영향이 없다.

나. 판결내용을 확정하는 절차

단독제의 경우에는 그 1인 법관이 판결내용을 정하게 되지만, 합의제의 경우에는 구성법관의 합의에 의하여 정한다. 합의는 재판장이 주재하며, 공개하지 않는다(법조 65조). 합의에 참여한 법관의 의견이 일치되지 않을 때에는 헌법 및 법률에 다른 규정이 없으면 과반수의 의견으로 결정한다(66조 1항). 다만 대법원의 전원합의체에서 2설 이상이 분립되어 어느 것도 과반수에 달하지 못한 때에는 원심재판을 변경할 수 없다(3항). 합의의 내용은 비밀이나, 대법원 재판서에는 합의에 참여한 모든 대법관이 의견을 표시하여야 한다(15조).

제30장

소
송
의
종
료

3. 판결서의 작성

가. 서 설

판결내용이 확정되면 법원은 이를 서면으로 작성하고 서명날인하여야 하는데, 이 서면을 판결서 또는 판결원본이라고 한다. 판결서에는 법률에 의하여 기재가 요구되는 필수적 기재사항(민소 208조)과 사무처리의 편의상 기재되는 임의적 기재사항이 있다. 이러한 판결서의 기재사항과 작성양식 등은 ‘재판서 양식에 관한 예규’, ‘판결서 작성방식의 개선을 위한 참고사항’, ‘판결서 작성방식에 관한 권장사항’ 등에 자세히 규정되어 있다.

나. 판결이유 기재의 간이화

판결서의 이유는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있는 정도로 당사자의 주장, 그 밖의 공격·방어방법에 관한 판단을 표시한다(민소 208조 2항). 따라서 법원의 판결에 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 표시되어 있지 않더라도 판결이유의 전반적인 취지에 비추어 그 주장을 인용하거나 배척하였음을 알 수 있는 정도라면 판단누락이라고 할 수 없고, 설령 실제로 판단을 하지 아니하였다고 하더라도 그 주장이 배척될 경우임

이 분명한 때에는 판결 결과에 영향이 없어 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2024. 10. 8. 선고 2024다241510 판결). 이는 민사소송법이 지향하는 심리방식은 심리의 충실을 1차적인 목표로 하고 있고, 변론준비절차나 변론의 진행과정에서 필요한 기록검토와 증거조사를 하고 당사자의 주장을 들어 쟁점 등을 정리하려면 많은 시간과 노력의 투입이 요구되는 점을 고려한 것이다. 즉 실질적인 심리의 충실을 이루기 위하여는, 법관 업무 중 지나치게 부담이 많았던 판결작성 업무의 비중을 경감시켜야 할 필요가 있기 때문에, 판결이유의 기재를 간이화한 것이다.

나아가 민사소송법은 합의·단독사건을 불문하고 제1심판결 중, ① 무변론 판결(민소 257조), ② 자백간주 판결(150조 3항), ③ 공시송달(194조 내지 196조)에 의한 사건의 판결에서는 기판력의 범위를 확정하기 위하여 청구를 특정함에 필요한 사항과 상계항변의 판단에 관한 사항(216조 2항) 이외에는 일반적으로 판결이유의 기재를 생략할 수 있도록 하고 있다(208조 3항).

또한 ① 항소심판결에 이유를 기재함에는 제1심판결을 인용할 수 있으며(민소 420조, 다만 제1심판결이 208조 3항에 따라 작성된 경우는 제외), ② 소액 사건의 판결서(소액 11조의2 3항), ③ 배상명령서(소촉 31조 2항), ④ 결정서와 명령서(민소 224조 1항 단서), ⑤ 상고심리불속행·상고이유서 부제출에 의한 상고기각 판결(상고심특례 5조 1항) 등에는 이유를 기재하지 않을 수 있다.

다. 변론종결일 및 판결선고일

판결원본의 당사자표시 다음에 판결의 기초가 되는 변론을 종결한 날짜를 기재한다(민소 208조 1항 5호). 다만 변론 없이 판결을 하는 경우에는 변론을 종결한 날짜 대신 판결을 선고하는 날짜를 기재한다(5호 단서). 이는 그 판결에서의 판단의 기준시점, 즉 기판력의 기준시를 명백히 표시하기 위한 것이다.

변론 없이 하는 판결에는 ‘변론종결일’란에 “무변론”이라고 표시한다. 여러 명의 피고 중 일부에 대하여만 변론 없이 하는 판결인 경우에는 변론을 거

친 피고에 대한 변론종결일을 먼저 표시한 다음 변론 없이 판결하는 피고에 대하여는 무변론이라는 취지를 표시한다(재판서예규 12조 3항).

재판서양식에 관한 예규는 선고하는 모든 판결의 주문 표시 윗줄에 판결 선고일을 표시하도록 하면서 위와 같이 판결선고일을 표시하는 판결에는 판결작성일을 생략하도록 하고 있다(재판서예규 13조, 17조 단서).

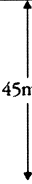
라. 법관의 서명날인

판결원본에는 판결내용의 결정에 관여한 법관, 즉 변론종결 당시 변론에 관여한 법관이 서명날인하여야 한다(민소 208조 1항, 204조 1항). 변론종결 당시의 변론에 관여하지 않고 단순히 선고에만 관여한 법관은 판결원본에 서명날인할 수 없다.

제30장

소
송
의
종
료

[판결서 기재례]



45mm

서 울 중 앙 지 방 법 원

제〇〇 민 사 부

판 결

시*****	건*****	2025가합123**대여금
원	고	김갑동*
		서울 서초구
		소송대리인*변호사*이삼수
피	고	이정*(李正)(이하 위와 같은 방식)
변*론*	중*결	2025.*4.*3.
판*결*	선*고	2025.*4.*17.

주***문**

← 20mm

1. 피고는 원고에게.....하라.

2.한다.

← 20mm

청*구*취*지

.....
..... 하라.

이 유

.....
..... 주문과 같이 판결한다.

↑
두 줄
↓

재판장

판사 ○○○
판사 ○○○
판사 ○○○

전자서명완료
전자서명완료
전자서명완료

↑
30mm
↓

※ *으로 표시된 글자간격은 예규에 규정되어 있는 것임

민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률 7조 2항과 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 7조 2항에 의하면, 법관이 재판서를 작성하는 때에는 법원 행정전자서명 인증업무에 관한 규칙 2조 2항에 따라 설치된 법원 행정전자서명 인증관리센터에서 발급받은 행정전자서명 인증서에 의한 사법전자서명을 하여야 한다. 이 사법전자서명은 민사소송 등에 적용되거나 준용되는 법령에서 정한 서명, 서명날인 또는 기명날인으로 본다(민전 7조 3항).

합의부의 경우, 법관이 판결원본에 서명날인하는 데 지장이 있는 때에는 재판장이, 재판장이 지장이 있는 때에는 서열이 가장 앞선 법관이, 일정한

양식에 따라 “판사 ○○○, 해외출장으로 서명날인 불능” 등의 식으로(재판서 예규 18조 5항) 그 사유를 적고 서명날인하여야 한다(민소 208조 4항). 이는 판결의 합의에는 관여하였지만 선고할 때까지 사이에 서명날인하는 데 지장이 있는 경우에 관한 편의규정이므로, 합의에도 관여하지 아니하였다면 위 규정이 적용될 여지가 없어 판결 자체를 할 수 없다.

한편 단독판사의 경우나 합의부의 법관 전원이 서명날인하는 데 지장이 있을 때에는 판결서를 작성할 수 없으므로, 종결한 변론을 재개하여 새로운 재판부가 변론을 갱신한 다음 판결하여야 한다.

4. 판결의 선고

가. 선고기일의 지정

소액사건의 경우에는 변론종결 후 즉시 판결을 선고할 수 있으나(소액 11조의2 1항), 그 밖의 사건의 경우에는 합의와 판결서 작성을 위하여, 변론종결 후 일정한 시간적 간격을 두고 별도의 기일을 선고기일로 지정하는 것이 보통이다. 법원은 변론을 연 경우는 물론이고 변론 없이 하는 경우에도 반드시 선고기일을 지정하고 당사자에게 기일통지서를 송달하여야 하는데, 이러한 절차를 거치지 않고 선고한 판결은 위법하다(대법원 1996. 5. 28. 선고 96누2699 판결).

선고기일은 원칙적으로 변론이 종결된 날부터 2주 이내이어야 하고, 복잡한 사건이나 그 밖의 특별한 사정이 있는 때에도 4주를 넘겨서는 아니 된다(민소 207조 1항). 또한 제1심판결은 소가 제기된 날부터 5월 이내에, 항소심 및 상고심 판결은 기록을 받은 날부터 5월 이내에 선고하여야 한다(199조). 그러나 이들 규정은 훈시규정이므로 이를 위반하였다고 하여 재판의 효력에 영향을 미치지 않는다(대법원 2008. 2. 1. 선고 2007다9009 판결).

선고기일은 변론을 종결하는 기일에 재판장이 지정한다. 무변론판결의 경우에는 피고에게 소장부분을 송달할 때에 무변론판결의 선고기일을 통지하

는 방식(민소 257조 3항)과 답변서 제출기한이 지난 후에 따로 선고기일을 지정하여 통지하는 방식 중 하나를 선택하여 선고기일을 지정·통지한다. 또한 무변론판결을 할 수 없거나 무변론판결에 적합하지 아니한 사건에 대하여 법원은 제1회 변론기일과 선고기일을 일괄 지정하여 당사자에게 기일통지서[전산양식 A1603]를 송달할 수 있고, 이 경우 피고가 답변서를 제출하지 아니하면 별도의 선고기일통지서를 송달하지 않고 지정된 선고기일에 판결을 선고할 수 있다(제1회 변론기일 및 선고기일 일괄 지정에 관한 예규 2조 본문, 3조).

나. 당사자에 대한 기일통지

선고기일도 기일의 일종이므로 당사자에게 선고기일통지서[전산양식 A1609]를 송달하여야 한다(민소 167조 1항 본문). 다만 그 선고기일이 재판장에 의하여 법정에서 지정될 때 출석하여 고지를 받은 사람에 대하여는 그러하지 아니하다(1항 단서). 변론종결 당시에는 선고기일을 구체적으로 지정하지 않았다가(이른바 추후지정) 후에 법정 외에서 지정하는 경우에는 모든 당사자에게 기일통지서를 송달하여야 한다. 일단 지정되었던 선고기일이 연기되거나 변경된 경우에는 새로이 지정된 기일에 대하여 다시 모든 당사자에게 통지하여야 한다.

법원이 적법하게 변론을 진행한 후 이를 종결하고 선고기일을 고지한 때에는 재정하지 아니한 당사자에게도 그 효력이 있고, 그 당사자에 대하여 선고기일의 기일통지서를 송달하지 아니하였다 하여도 위법하다고 할 수 없다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2002다72514 판결). 선고기일을 추후에 지정하기로 하였다가 새로 지정한 선고기일에 관하여 적법한 통지 및 출석요구가 이루어지지 않은 채 판결이 선고된 경우에도 그와 같은 위법은 판결에 아무런 영향이 없다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2001다14023 판결). 한편 선고기일통지서가 송달불능되거나 그 송달보고서가 도착하지 않은 경우에도 선고기일을

연기함이 없이 그 기일에 선고할 수 있다.

다. 선 고

판결은 선고로 효력이 생긴다(민소 205조). 변론을 거치지 아니한 판결이라도 상고인이 상고이유서를 제출하지 아니한 경우에 하는 상고기각 판결과 상고심에서의 심리불속행 판결(상고심특례 5조 2항) 외에는 선고가 반드시 필요하다. 판결의 선고는 기일에 공개된 법정에서 하여야 하는데(법조 57조 1항), 당사자가 출석하지 아니하여도 할 수 있고(민소 207조 2항), 소송절차가 중단되어 있는 때에도 할 수 있다(247조 1항). 당사자의 출석 여부를 확인하지 아니하는 것이 실무의 관행이나, 실제로 당사자들이 출석하는 경우가 있으므로 출석이 확인되는 당사자가 있는 때에는 정식으로 당사자를 법대 앞으로 나오게 하여 판결을 선고하고 조서에도 출석사실을 기재하여야 한다.

판결을 선고함에는 재판장이 판결원본에 의하여 주문을 읽어야 한다(민소 206조). 판결주문을 그대로 읽어야 하고, ‘원고 승소’, ‘원고 패소’ 등으로 결과만 말하여서는 아니 된다. 주문이 복잡할 때에는 낭독 후 그 취지를 간략히 덧붙여 설명하는 것이 바람직하다. 판결서는 원본이 전자문서로 작성되므로 그 원본의 성립 시기는 사법전자서명을 마친 때이다.

이유의 요지는 설명하지 아니함이 원칙이나, 필요한 때에는 간략히 설명할 수 있다(민소 206조). 특히, 당사자가 다수이고 이해관계가 첨예하게 대립되어 재판진행에 많은 관심을 보여 왔고 선고기일에도 출석하는 등 특별한 사정이 있을 때에는 이유의 요지를 설명함이 바람직하다.

소액사건의 경우에는 판결서에 이유를 기재하지 아니할 수 있는 대신에, 판결선고 시에는 주문을 낭독하고 주문이 정당함을 인정할 수 있는 범위 안에서 그 이유의 요지를 말로 설명하여야 함에 주의하여야 한다(소액 11조의2). 당사자가 모두 불출석한 경우에는 물론 설명을 요하지 않는다.

민사소송규칙에는 판결서의 정보를 송달하는 때에 법원사무관등이 상소기

간과 상소장을 제출할 법원을 고지하도록 규정되어 있다(민소규 55조의2). 실무에서는 판결서의 정본 말미에 이를 미리 인쇄하여 송달하고 있으므로, 판결선고 시에는 판결에 대한 불복방법을 따로 고지할 필요가 없다.

라. 선고조서의 작성

판결의 선고는 조서의 실질적 기재사항에 속하므로(민소 154조 6호) 판결이 선고된 때에는 판결선고조서[전산양식 A1667]를 작성하여야 한다. 당사자의 출석 여부는 출석이 확인되는 대로 정확히 기재하여야 한다. 무변론판결을 선고할 때에는 특히 피고의 출석 여부를 확인하는 것이 바람직하다.

판결선고조서의 '본문'란에는 "판결원본에 의하여 판결선고"라고 기재한다. 재판부의 법관 표시는 판결서에 표시된 법관이 아니라 실제로 선고에 관여한 법관의 성명을 기재하여야 한다.

5. 판결선고 후의 절차

가. 판결원본의 교부 등

재판장은 판결을 선고한 뒤에 바로 법원사무관등에게 판결서를 교부하여야 한다(민소 209조). 이는 판결정본 송달 등 사무처리의 원활을 기하기 위한 것인데, 전자문서로 작성되는 판결서는 사법전자서명을 한 후 전산정보처리시스템에 등재함(민전 7조 2항, 10조 1항)으로써 위와 같은 법원사무관등에 대한 판결서 원본의 교부절차를 같음하게 되었다. 이와 같이 전산등재된 판결서 원본에 대해서는 법원장의 공람을 받는데, 법원사무관등은 공람이 완료되기 전이라도 판결문을 송달할 수 있으며, '판결서 수령 및 송달상황부'는 별도로 작성하지 아니한다(민전예규 98조).

나. 판결정본의 송달

판결정본을 작성하는 때에는 장마다 간인을 하고, 정본 말미용지[전산양식

A2750]를 사용하는 경우에는 해당란에 법원사무관등이 기명날인(직인을 날인한다)하여야 한다(민소 162조 6항). 다만 직인날인에 갈음하여 전자이미지 직인을 사용할 수 있고(재판서 정보 등의 작성에 관한 예규 2조), 재판사무시스템에 의하여 판결정보를 출력할 경우에는 발급번호기재방식으로 간인에 갈음할 수 있다(3조 2항).

판결정보는 당사자 전원(원고·피고·독립당사자참가인)은 물론 보조참가인에게도 송달하여야 한다. 선정당사자 기타 타인을 위해 원·피고로 된 자가 받은 판결은 그 타인에게에는 송달할 필요가 없다. 소송대리인이 있을 경우에는 그 소송대리인에게만 송달하면 된다. 국가를 당사자로 하는 소송에서 국가에 대한 송달은 수소법원에 대응하는 검찰청(수소법원이 지방법원 지원인 경우에는 지방검찰청을 말한다)의 장에게 하되, 고등검찰청 소재지의 지방법원(산하 지방법원 지원을 포함한다)에 소가 제기된 경우에는 그 고등검찰청의 장에게 송달한다(국당 9조). 이에 위반하여 법무부장관에게 판결정보를 송달한 것은 부적법하고 이러한 흠은 이의권 상실의 대상이 아니다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2001다84497 판결).

법원사무관등은 판결을 받은 날부터 2주 이내에 당사자에게 송달하여야 한다(민소 210조). 법원사무관등이 판결서의 정보를 송달하는 때에는 모든 당사자에게 상소기간과 상소장을 제출할 법원을 고지하여야 한다(민소규 55조의 2). 구체적으로는 고지사항이 포함되어 있는 **정보 말미용지[전산양식 A2750]**를 판결정보 뒤에 첨부하여 함께 송달하는 방법을 사용하고 있다. 이러한 고지는 당사자의 편의를 도모하기 위한 것이고 법원사무관등이 누락하였다 하더라도 판결선고의 효력이나 상소기간의 진행에는 영향이 없다. 한편 보조참가인과 피참가인이 판결을 송달받은 날이 다른 경우, 보조참가인의 상소기간은 피참가인의 상소기간에 한정된다(대법원 1969. 8. 19. 선고 69다949 판결).

판결선고 직후에 소가 취하된 경우, 이와 동시에 피고의 동의가 있으면 소

취하와 함께 소송이 종료되므로 판결정본의 송달은 필요 없으나, 그 동의가 없으면 우선 피고에게 취하서 부분을 송달하고 이와 별도로 양쪽 당사자에게 판결정본을 송달하여야 한다. 이 경우 상소기간(판결정본 송달 시로부터 2주) 내에 피고의 동의가 있거나 동의간주(취하서 부분 송달 시로부터 2주 경과)된 때에는 사건은 소의 취하에 의하여 종료된 것으로 처리하고, 상소기간이 경과될 때까지 동의나 동의간주가 없으면 판결의 확정에 의하여 소송은 종료된다.

다. 상소된 경우의 처리

판결에 대하여 상소가 제기되면 그 판결은 확정이 차단되고 상급법원에서 그 당부가 심사된다. 이 경우 원심법원의 법원사무관등은 사건이 당해 심급을 이탈하므로, 신속히 기록을 정리하여 상급법원의 법원사무관등에게 송부하여야 한다. 판결서는 그 원본을 기록에 편철하여 송부한다. 일부판결에 대하여 상소가 제기된 때에는 인증등본을 송부한다.

자세한 기록송부절차에 관하여는 제7장(문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무) 제3절 참조.

라. 확정된 경우의 처리

판결이 확정된 경우에는 완결기록으로서의 인계 및 보존절차가 취해져야 하는바, 그 자세한 내용은 제7장(문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무) 제3절 참조.

6. 판결의 확정

가. 의 의

‘판결의 확정’이란 법원이 한 종국판결에 대하여 당사자의 불복으로 상소법원에 의하여 취소할 수 없게 된 상태를 말하고(민소 498조), 이러한 취소불

가능성을 형식적 확정력이라 한다. 판결의 확정은 판결정본이 적법하게 송달되었을 것을 전제로 한다(대법원 1997. 5. 30. 선고 97다10345 판결). 판결의 형식적 확정력은 상소의 추후보완(173조)이나 재심의 소(451조)에 의하여 배제될 수 있다.

나. 판결의 확정시기

(1) 판결선고와 동시에 확정되는 경우

상소할 수 없는 판결, 예컨대 상고심판결, 제권판결(민소 490조 1항) 등은 그 선고와 동시에 확정된다. 제권판결에 대하여는 별도로 불복소송이 가능하므로, 실질적으로 확정되기 위해서는 불복소송의 제기기간이 경과하여야 한다. 판결선고 전 불상소의 합의가 있는 때에도 그러하나, 판결선고 후 불상소의 합의를 한 경우에는 이미 발생한 상소권의 포기를 합의한 것이므로 그 성립과 동시에 판결이 확정된다. 다만 비약상고(390조 1항 단서)의 합의가 있는 때에는 상고기간의 만료시에 확정된다.

(2) 상소기간 만료시에 확정되는 경우

- ① 상소기간 내에 상소를 제기하지 않고 기간이 경과한 때
- ② 상소를 제기하였으나 상소를 취하한 때
- ③ 상소를 제기하였으나 상소각하판결 또는 상소장각하명령이 있는 때(물론 이들 재판이 확정되었을 것을 전제로 한다. 항소이유서 부제출로 인한 항소장각하결정이 있을 때도 마찬가지이다)

(3) 기 타

상대방이 전부승소하여 상소의 이익이 없는 경우 상소기간 도과 전에 상소권을 가진 패소자가 이를 포기한 때(민소 394조, 425조)에는 비록 상대방의 상소기간이 만료하지 않았더라도 불복의 대상이 된 판결은 그 포기시에 확정된다(대법원 2006. 5. 2. 자 2005마933 결정). 상소기각판결은 그것이 확정된 때 원판결이 확정된다.

다. 판결의 확정범위

1개의 판결 일부에 대하여 상소한 경우라도 판결 전부에 대하여 확정차단의 효력이 생기고, 여러 개의 청구에 대한 1개의 판결이 있는 경우에 일부의 청구에 대하여만 상소가 있어도 확정차단의 효력은 판결 전부에 대하여 생긴다(상소불가분의 원칙). 다만 통상공동소송에서 상소로 인한 확정차단의 효력은 상소인과 그 상대방에 대해서만 생기고, 다른 공동소송인에 대한 청구에 대하여는 미치지 아니한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009다7076 판결).

수개의 청구에서 패소한 당사자가 그중 일부에 대하여만 항소를 제기한 경우, 항소되지 않은 나머지 부분도 확정이 차단되고 항소심에 이심은 되나, 그 항소인이 변론종결 시까지 항소취지를 확장하지 않는 한 그 나머지 부분에 관하여는 불복한 바가 없어 항소심의 심판대상이 되지 않고 항소심의 판결선고와 동시에 확정되어 소송이 종료된다(대법원 1994. 12. 23. 선고 94다44644 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다35842 판결). 한편 대법원의 환송판결이 일부 부분만 파기환송하고 나머지 상고를 기각하였다면, 파기환송되지 않은 부분은 환송판결의 선고로써 확정된다(대법원 1995. 3. 10. 선고 94다51543 판결).

라. 판결의 확정증명

판결이 확정되면 소송당사자는 그 판결에 기하여 기판력을 주장하거나, 가족관계등록 관련 신고·등기신청 등을 하기 위하여 판결이 확정되었음을 증명할 필요가 있다. 당사자는 소송기록을 보관하고 있는 법원사무관등에게 신청하여 판결확정증명서를 교부받게 된다.

상급법원에서 소송이 완결된 경우에도 소송기록은 제1심법원에서 보관하므로(민소 421조, 425조), 확정증명서의 교부는 제1심법원의 법원사무관등으로부터 교부받는 것이 원칙이다(499조 1항). 다만 소송이 상급법원에 계속 중이라도 그 사건의 일부가 확정된 경우에는 소송기록이 상급법원에 있기

때문에, 그 확정부분에 대한 증명서는 상급법원의 법원사무관등으로부터 교부받게 된다(2항). 전자소송 사건에서는 전자소송포털에서 직접 확정증명을 발급받을 수 있다.

판결확정증명의 구체적인 절차는 제8장(소송기록의 열람·복사 및 공증사무) 참조.

마. 소송의 종료

판결이 형식적으로 확정되면 소송은 종국적으로 종료된다. 확정에 의하여 판결의 내용에 따른 효력인 기판력·집행력·형성력 등이 생기게 된다.

제30장

소송의
종료

7. 판결의 경정

가. 서 설

판결의 경정이란 판결내용을 실질적으로 변경하지 않는 범위 내에서 판결에 잘못된 계산이나 기재, 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있음이 분명한 때에 판결법원이 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 결정으로 그 잘못을 바로 잡는 것을 말한다(민소 211조). 그리하여 강제집행, 가족관계등록사항·등기사항의 기재 등 넓은 의미의 집행에 지장이 없도록 해주자는 취지이다(대법원 2000. 5. 30. 자 2000그37 결정).

잘못은 판결법원의 표시, 당사자, 주문, 변론종결 연월일, 이유 등 판결의 어느 부분에 있는지에 관계없이 경정이 가능하다. 법원의 과실이 아니고 당사자의 과실로 인하여 생긴 잘못, 예컨대 당사자가 소제기 시에 소송목적물의 지번이나 지적 등을 잘못 표시하여 판결에 그대로 기재된 경우에도 경정할 수 있다는 것이 실무와 판례이다(대법원 1990. 5. 23. 자 90그17 결정). 경정결정은 청구의 포기·인낙조서 및 화해조서(민소 220조)뿐만 아니라 이행권고결정(대법원 2022. 12. 1. 자 2022그18 결정) 등 결정과 명령에도 준용된다(224조).

나. 경정의 요건

판결에 잘못된 계산이나 기재, 그 밖에 이와 비슷한 표현의 잘못이 있고 또 그 잘못이 분명하여야 한다. 분명한 잘못인가의 여부는 판결서의 기재뿐만 아니라 소송기록과 대비하여 판단하여야 하고, 나아가 경정대상인 판결 이후에 제출된 자료나 집행과정에서 밝혀진 사실도 판단자료가 된다(대법원 2000. 5. 24. 자 98마1839 결정).

판례상 인정된 경정사유는, 당사자의 표시에 주소가 누락된 채 송달장소만이 기재된 경우(대법원 2000. 5. 30. 자 2000그37 결정), 채권자대위소송에서 채무자의 주소가 누락된 경우(대법원 1995. 6. 19. 자 95그26 결정), 판결서 말미에 별지 목록이 누락된 경우(대법원 1989. 10. 13. 선고 88다카19415 판결), 목적물의 표시에서 번지의 호수가 누락된 경우(대법원 1964. 4. 13. 자 63마40 결정), 건물의 바닥면적이나 토지의 면적이 잘못 표시된 경우(대법원 1985. 7. 15. 자 85그66 결정), 구 지적법(현 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률)상 허용되지 않는 m^2 미만의 단수를 판결에 그대로 표시한 경우(대법원 1996. 10. 16. 자 96그49 결정), 토지에 관한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소송 중 사실심 변론종결 전에 토지가 분할되었는데도 그 내용이 변론에 드러나지 않은 채 원고 청구가 인용된 경우(대법원 2001. 10. 19. 자 2001마4618 결정), 호프만식 계산법에 의한 손해배상금의 계산이 잘못된 경우(대법원 1970. 1. 27. 선고 67다774 판결), 판결주문 중 등기원인 일자가 잘못 표시된 경우(대법원 1970. 3. 31. 선고 70다104 판결), 채권자가 이미 사망한 자를 그 사망사실을 모르고 제3채무자로 표시하여 채권압류 및 전부명령을 신청한 사안에서 채권압류 및 전부명령의 제3자 표시를 사망한 자에서 사망자의 상속인으로 고치는 경우(대법원 1998. 2. 13. 선고 95다15667 판결), 항소심에서 항소를 일부 받아들여 제1심판결을 변경하면서 나머지 항소를 기각한다는 주문을 누락한 경우(대법원 2014. 10. 30. 자 2014스123 결정), 명의신탁 해지를 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행 등을 구하는 소에서

주문의 상속지분을 잘못 기재한 경우(대법원 2024. 6. 13. 자 2024그548 결정) 등이다.

또한 판례는 청구변경이 소의 추가적 변경에 해당하는데 원심이 기존의 청구와 추가된 청구를 모두 판단하면서도 청구변경의 취지를 교환적 변경으로 단정하여 주문에서 ‘원심에서 교환적으로 변경된 이 사건 소를 각하한다’고 기재한 경우, 위 주문은 ‘제1심판결을 취소하고 원심에서 확장된 부분을 포함하여 이 사건 소를 각하한다’고 할 것을 잘못 기재한 것임이 명백하므로 이는 판결의 경정사유에 불과하고 파기사유는 아니라고 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결). 조정조서에 첨부된 도면이 한국국토정보공사(구 대한지적공사)에서 측량한 측량성과도가 아니라는 이유로 수리가 거부되어 조정조서 집행이 곤란해지자 당사자 일방이 한국국토정보공사(구 대한지적공사)에 그 도면과 같은 내용으로 지적현황측량을 의뢰하여 그 측량성과도로 별지 도면을 작성한 후 신청한 경우에는 조정조서의 경정을 허가하여야 한다(대법원 2012. 2. 10. 자 2011마2177 결정).

한편 표현상의 명백한 잘못이 아닌 판단내용의 잘못이나 판단누락은 경정사유가 되지 않는다. 판례상 경정사유가 되지 않는 것은, 청구원인에서 원금을 구하더라도 청구의 취지에서 원금을 누락하였는데 판결경정으로 원금 부분을 추가하는 경우(대법원 1995. 4. 26. 자 94그26 결정), 환지확정에 따라 청구취지를 정정하면서 누락된 종전 토지의 일부를 추가하는 경우(대법원 1996. 3. 12. 자 95마528 결정), 과거 양육비 액수가 여러 사정에 비추어 과다하다고 볼 여지가 있다고 하더라도 과거 양육비 액수를 대폭 감액하는 경우(대법원 2024. 5. 30. 자 2023스774, 775 결정), 이행권고결정 또는 판결서에 당사자의 주민등록번호를 추가하여 달라는 경우(대법원 2022. 12. 1. 자 2022그18 결정, 대법원 2022. 9. 29. 자 2022그637 결정. 당사자는 판결서에 기재된 당사자의 주소에 주민등록을 마친 적이 있다면 주민등록법 29조 2항 2호에 따라 주민등록표 등초본을 발급받을 수 있고, 민사소송규칙 76조의2에서 정한 절차에 따

라 재판사무시스템에 소송관계인의 주민등록번호를 추가하거나 수정하도록 할 수 있다) 등이다.

다. 경정의 시기

경정결정의 시기에 관하여는 제한이 없다. 따라서 상소제기 또는 판결확정의 전후를 불문한다. 강제집행 단계에서 비로소 오류를 발견하였더라도 경정신청을 할 수 있다.

라. 경정법원

경정결정은 원칙적으로 당해 판결을 한 법원이 한다. 상소에 의하여 사건이 상급법원으로 이심된 경우에는 소송기록이 있는 상급법원에서도 경정결정을 할 수 있으나, 하급심에서 확정된 판결 부분에 관하여는 상급법원에서 경정할 수 없다(대법원 1992. 1. 29. 자 91마748 결정).

마. 처리절차

(1) 신청에 의하는 경우

판결경정신청서에는 인지를 붙일 필요가 없으며(인지액·편철방법예규), 결정정본의 송달에 필요한 비용을 예납하여야 한다. 판결경정신청이 있으면 접수사무관등은 신청사건으로 전산입력하고 별개의 민사신청사건번호와 표지를 붙여 법원사무관등에게 인계하고, 법원사무관등은 그 신청기록을 본안 사건기록에 첨철하여 지체 없이 재판부에 회부하여야 한다. 피고 표시 경정신청에 있어 피고와 경정을 구하는 상대방이 동일인일 상당한 개연성이 있는 경우에, 동일인인지 여부를 심리한 후 경정 여부를 심리하여야 한다(대법원 2001. 12. 4. 자 2001그112 결정).

(2) 직권에 의하는 경우

이때에는 독립된 사건번호를 부여하지 아니하며, 따라서 사건기록도 별개로

편성하지 않고 경정결정원본은 본안사건기록에 가철한다.

바. 경정의 방법

민사소송법에는 경정결정은 판결의 원본과 정본에 덧붙여 적도록 하고 있으나(민소 211조 2항), 실제로는 그러한 예는 실무상 거의 없고, 따로 경정결정서를 작성하여 그 결정정본을 송달하는 것이 일반적이다(2항 단서).

원본에는 이상이 없으나 정본에만 오류가 있을 때에는 법원사무관등이 정정하면 되는데(민소 162조 1항, 6항 참조), 이는 물론 판결경정이 아니다.

사. 경정결정의 효력

경정결정서는 송달에 의하여 경정결정 자체의 효력이 생기지만, 잘못이 시정되는 경정의 효력은 경정결정 자체의 효력과는 달리 판결선고 시에 소급하여 생긴다(대법원 1962. 1. 25. 자 4294민재항674 결정). 그러므로 판결에 대한 상소기일은 경정결정에 의하여 영향을 받지 않고 판결이 송달된 날부터 진행한다. 경정한 결과 상소이유가 발생한 경우에는 상소의 추후보완(민소 173조)을 할 수 있는데, 상소기간 경과 후에 이루어진 판결경정 내용이 경정 이전에 비하여 불리하다는 사정만으로 상소의 추후보완이 허용되는 것은 아니다(대법원 1997. 1. 24. 선고 95므1413 판결).

채권가압류결정의 경정결정이 확정된 경우에는, 원칙적으로 당초의 채권가압류결정 정본이 제3채무자에게 송달된 때 소급하여 효력이 발생하나, 채권가압류결정의 경정결정이 제3채무자의 입장에서 볼 때 객관적으로 당초결정의 동일성에 실질적 변경을 가하는 것이라고 인정된다면, 경정결정이 제3채무자에게 송달된 때 비로소 경정된 내용의 가압류의 효력이 발생한다(대법원 1999. 12. 10. 선고 99다42346 판결). 그리고 판결이 경정되면 당초의 원판결과 일체가 되어 처음부터 경정된 내용의 판결이 있었던 것과 같은 효력이 있으므로 불이익변경금지의 원칙은 경정된 판결을 기준으로 하여 적용

된다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2011다41796 판결).

[경정결정 기재례]

○ ○ 법 원

제 ○ 민 사 부

결 정

사 건 20○○카기15 판결경정

신 청 인 ○○○

(원 고) 서울 서초구 ……

피신청인 ○○○

(피 고) 서울 강남구 ……

주 문

위 당사자 간의 이 법원 2023가합101 대여금사건에 관하여 2024. 10. 10. 선고한 판결의 주문 제1항 중 “○○”를 “△△”로, 이유 중 판결서 제5면 제8행의 “△△”를 “××”로 각 경정한다.

이 유

위 판결에 명백한 오류가 있으므로 민사소송법 제211조에 의하여 주문과 같이 결정한다.

20○○. ○. ○.

재판장 판사 ○○○

판사 ○○○

판사 ○○○

* 주 : 직권에 의한 경정결정일 때에는 사건표시를 본안사건의 번호와 사건명으로 기재하고, 당사자도 원고·피고로만 표시하며, 주문은 “이 사건에 관하여 2024. 10. 10. 선고한 판결의…”로 한다.

아. 불복절차

경정결정에 대하여는 불이익을 받는 당사자가 즉시항고할 수 있으나(민소

211조 3항), 경정신청을 기각한 결정에 대하여는 불복할 수 없고 만약 항고가 있을 때는 이를 특별항고(449조)로 보아 대법원으로 기록을 송부하여야 한다(대법원 1995. 7. 12. 자 95마531 결정). 그 특별항고가 인용되기 위해서는, 신청인이 그 재판에 필요한 자료를 제출할 기회를 전혀 부여받지 못한 상태에서 그러한 결정이 있었다든가, 판결과 그 소송의 전 과정에 나타난 자료 및 판결선고 후에 제출된 자료에 의하여 판결에 오류가 있음이 분명하여 판결이 경정되어야 하는 사안임이 명백함에도 불구하고, 법원이 이를 간과함으로써 기각 결정을 한 경우 등이 이에 해당된다(대법원 2004. 6. 25. 자 2003그136 결정, 대법원 2011. 10. 28. 자 2011그184 결정).

경정결정이 있었다 하더라도 당해 판결에 대하여 적법한 항소가 제기된 때에는 경정결정에 대하여 즉시항고를 할 수 없다(민소 211조 3항 단서). 이는 항소심에서 원판결의 당부를 심사할 때 경정결정도 함께 심사를 받게 되기 때문이다(대법원 1991. 5. 1. 자 90그67 결정).

제3절 소의 취하

1. 개 설

소의 취하는 원고가 소의 전부 또는 일부를 철회하는 법원에 대한 단독적 소송행위이다(대법원 2004. 7. 9. 선고 2003다46758 판결). 소가 주관적 또는 객관적으로 병합되어 있는 수개의 청구 중(단 고유필수적 공동소송의 경우는 제외) 일부는 물론, 1개의 청구 중 일부도 취하할 수 있다(민소 266조 1항). 주관적·예비적 공동소송의 경우 공동소송인 중 일부가 소를 취하하거나 상대방이 일부 공동소송인에 대한 소를 취하할 수 있다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2015다242429 판결). 소송상 청구금액을 감축한다는 것은 소의 일부 취하를 뜻하는 것으로서 취하된 부분의 청구를 포기하였다고는 볼 수 없다(대법

원 1983. 8. 23. 선고 83다카450 판결).

소의 취하는 상소의 취하와는 구별하여야 한다. 상소의 취하는 원판결을 그대로 유지·확정시키는 데 반하여 소의 취하는 이미 행한 판결도 실효하게 한다. 상소의 취하에는 피상소인이 응소하였다 하더라도 그의 동의가 필요 없다.

소송 외에서 원고가 피고에 대하여 소를 취하하기로 하는 약정을 소취하 계약 또는 소취하합의라고 하는데, 이러한 약정이 있는 경우 법원은 권리보호의 이익이 없음을 이유로 소를 각하하여야 한다(대법원 1982. 3. 9. 선고 81다1312 판결).

양쪽 당사자의 변론(준비)기일 불출석에 의한 소취하간주에 관하여는 제 19장(기일과 기간) 참조.

2. 요 건

가. 소송물

원고는 가사소송 등 직권탐지주의의 적용을 받는 소송물에 대하여도 자유롭게 취하할 수 있다. 다만 주주가 주주대표소송을 제기한 경우 법원의 허가를 얻지 아니하고는 소의 취하를 할 수 없으며(상법 403조 6항), 증권관련 집단소송에서의 소의 취하도 법원의 허가를 받지 않으면 효력이 없다(증집 35조 1항).

나. 시 기

소의 취하는 소제기 후 종국판결의 확정에 이르기까지 할 수 있으므로(민소 266조 1항), 항소심·상고심에서도 할 수 있으나 본안에 대한 종국판결이 있는 뒤에 소를 취하하면 재소금지의 제재가 따른다(267조 2항). 소송요건의 흠이 있어 유효한 소가 아니더라도 이를 취하할 수 있다.

다. 유효한 소송행위

원고가 소를 취하하려면 소송능력이 있어야 하고, 법정대리인 또는 소송대리인이 소를 취하하려면 특별한 권한을 따로 받아야 한다(민소 56조 2항, 90조 2항). 다만 소송무능력자 또는 무권대리인은 추인이 없는 한 스스로 제기한 소를 취하할 수 있고 피고가 본안에 관하여 변론을 한 경우에도 그 동의를 얻을 필요가 없다. 소의 취하는 소송행위이므로 조건을 붙여서는 아니 된다.

소의 취하는 소송행위이므로 사기·강박(대법원 1980. 8. 26. 선고 80다76 판결)이나 착오(대법원 1997. 6. 27. 선고 97다6124 판결)를 이유로 소취하의 철회나 무효·취소를 주장할 수 없다. 그러나 소의 취하가 형사상 처벌받을 다른 사람의 행위로 인하여 이루어진 경우에는 무효·취소를 주장할 수 있다(대법원 1985. 9. 24. 선고 82다카312 판결). 이 경우 다른 사람의 행위에 대하여 유죄판결이 확정되고 또 그 소송행위가 그에 부합되는 의사 없이 외형적으로만 존재할 때에 한하여 민사소송법 451조 1항 5호를 유추하여 그 효력을 부인할 수 있다(대법원 2001. 1. 30. 선고 2000다42939 판결).

라. 피고의 동의

상대방이 본안에 관하여 준비서면(피고가 제출한 답변서도 포함된다)을 제출하거나 변론준비기일에서 진술하거나 변론을 한 뒤에는 상대방의 동의를 받아야 취하의 효력이 생긴다(민소 266조 2항). 본소의 취하 후에 반소를 취하함에는 원고의 동의가 필요 없다(271조).

소취하의 동의는 소송행위이므로 소송능력이 있어야 하며, 조건을 붙여서는 아니 된다. 소취하에 대한 소송대리인의 동의는 소송대리권의 범위 내의 사항으로서 특별수권사항이 아니므로 바로 본인에게 그 효력이 미친다(대법원 1984. 3. 13. 선고 82므40 판결). 양쪽 당사자를 상대로 한 독립당사자참가를 취하함에 있어서는 원·피고 쌍방의 동의를 요하나(대법원 1981. 12. 8. 선고 80다577 판결), 참가인이 쌍면참가를 하였다가 당사자 한쪽 예컨대 피고의

동의하에 피고에 대해서만 참가신청을 취하한 경우에는 원고에 대한 편면참가가 된다. 독립당사자참가 후에 원고가 본소를 취하함에는 피고의 동의 외에 참가인의 동의를 필요로 한다(대법원 1972. 11. 30. 자 72마787 결정).

소의 일부 취하(청구의 감축)에 대하여 피고가 이의를 진술하지 않고 소송을 진행시키는 경우에는 묵시적인 동의가 있다고 인정된다. 일단 피고가 동의를 거절하였으면 소취하의 효력이 생기지 아니하므로, 후에 다시 동의하더라도 소취하의 효력이 생기지 않는다(대법원 1969. 5. 27. 선고 69다130 판결).

3. 방 법

가. 취하의 방법

원칙적으로 소송이 계속된 법원에 취하서를 제출하여야 한다(민소 266조 3항 본문).

변론기일 또는 변론준비기일에서는 말로 소를 취하할 수 있다(민소 266조 3항 단서). 소의 취하는 법원에 대한 단독행위이므로 상대방이 불출석하여도 할 수 있고, 말로 소를 취하한 경우에 상대방이 불출석한 경우에는 취하의 진술을 기재한 조서의 등본을 상대방에게 송달하여야 한다(5항). 소의 취하는 조서의 필수적 기재사항이므로(154조 1호) 말로 소를 취하한 때에는 “원고, 소취하”라고 기재한다. 일부만 취하하였을 경우에는 그 취하된 부분을 특정하여 명기한다. 앞에서 본 바와 같이 상대방의 동의가 소취하의 효력발생요건이 되는 수가 있으므로 상대방이 출석한 경우에는 그 동의 여부도 기재하여야 한다.

나. 동의의 방법

소취하에 대한 상대방의 동의도 서면 또는 말로 한다. 상대방의 동의 여부가 명확하지 아니한 경우에는, 취하의 서면이나 조서등본이 송달된 날부터 2주 이내에, 말로 취하하고 상대방이 기일에 출석한 경우에는 취하한 날부

터 2주 이내에 이의를 제기하지 않으면 소의 취하에 동의한 것으로 본다(민소 266조 6항).

4. 효 력

가. 효력의 발생시기

상대방이 본안에 관하여 응소하기 전에 소를 취하한 경우에는 소취하서를 법원에 제출한 때 또는 말로 소를 취하한다고 한 때에 효과가 발생한다. 상대방이 본안에 관하여 응소한 후에 소를 취하한 경우에는, 상대방이 이에 동의한 때 또는 동의가 있다고 간주되는 때에 효과가 발생한다.

나. 소송계속의 소급적 소멸

소가 취하되면 처음부터 소송이 계속되지 아니하였던 것과 같은 상태에서 소송이 종료된다. 그러나 소취하에 앞서 제기한 독립당사자참가·반소·중간 확인의 소는 본소의 취하에 불구하고 원칙적으로 아무런 영향을 받지 아니하며(반소에 관하여는 대법원 1970. 9. 22. 선고 69다446 판결, 독립당사자참가에 관하여는 대법원 1991. 1. 25. 선고 90다4723 판결), 소송계속에 바탕을 둔 관련재판적은 본소가 취하되어도 소멸되지 않는다(민소 33조). 독립당사자참가소송에서 본소가 적법하게 취하된 경우에는 삼면소송관계는 소멸하고, 이후부터는 당사자참가인의 원·피고들에 대한 청구가 일반 공동소송으로 남아 있게 되므로, 당사자참가인의 원·피고에 대한 소가 독립의 소로서의 소송요건을 갖춘 이상 그 소송계속은 적법하며, 종래의 삼면소송 당시에 필요하였던 당사자 참가요건의 구비 여부는 가려 볼 필요가 없다(대법원 1991. 1. 25. 선고 90다4723 판결).

소의 제기에 의한 실체법적 효과인 시효중단과 제소기간 준수의 효과는 소취하에 의하여 소급적으로 소멸된다(민법 170조). 소송에서 공격방어방법의 전제로 형성권을 행사한 경우 소의 취하에 의하여 형성권 행사의 효력이 소멸되는지에 대하여는 견해의 대립이 있는데, 판례는 소제기로써 계약해제

권을 행사하고 그 소장이 피고에게 송달되었는데 그 후 원고가 소송을 취하하였다 하여도 해제권 행사의 효력에는 아무런 영향을 미치지 아니한다고 한다(대법원 1982. 5. 11. 선고 80다916 판결). 또한 선정당사자 본인에 대한 부분의 소가 취하되면 공동의 이해관계가 소멸하여 선정당사자는 그 자격을 당연히 상실한다(대법원 2006. 9. 28. 선고 2006다28775 판결).

소가 취하되어 소송이 종료되었더라도, 법원은 당사자의 신청에 의하여 결정으로 소송비용의 부담과 액수를 정하여야 한다(민소 114조 1항). 원칙적으로 피고가 채무를 이행하였기 때문에 소를 취하한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한(대법원 2020. 7. 17. 자 2020카합522 결정) 원고를 패소자에 준하여 소송비용의 전액을 부담시킬 것이다(2항, 98조).

원고가 당해 심급의 변론종결 전에 소를 취하한 때에는 3년 이내에 소제기 당시 납부한 인지액의 2분의 1에 해당하는 금액(인지액의 2분의 1에 해당하는 금액이 10만 원 미만이면 인지액에서 10만 원을 빼고 남은 금액)의 환급을 청구할 수 있다(인지 14조).

다. 재소의 금지

(1) 의 의

소가 취하되면 소송계속이 소급적으로 소멸되므로 재차 같은 소를 제기할 수 있다. 그러나 종국판결을 선고한 뒤에 소를 취하한 다음 다시 재소의 제기를 허용한다면 본안판결에 이르기까지 법원이 들인 노력과 비용이 무용지물이 되고 법원의 종국판결이 당사자에 의하여 농락당할 수 있으므로, 본안에 관하여 종국판결이 있는 뒤에는 이미 취하한 소와 같은 소를 제기할 수 없다(민소 267조 2항).

(2) 같은 소

가) 당사자의 동일

재소를 제기할 수 없는 것은 전소의 원고만이고, 피고는 재소의 제기에 제

한을 받지 않는다. 전소 원고의 포괄승계인은 물론 변론종결 후의 특정승계인도 재소를 제기할 수 없다(대법원 1981. 7. 14. 선고 81다64 판결). 소를 취하한 자가 선정당사자일 때에는 선정자도 재소금지의 효과를 받는다. 본안 판결 후에 취하한 자가 채권자대위소송을 한 채권자일 때에는 채무자가 대위소송이 제기된 것을 안 이상 채무자도 재소금지의 효과를 받는다(대법원 1996. 9. 20. 선고 93다20177 판결). 대위채권이 없어 대위자격이 없는 자가 채무자에게 이행청구를 함과 아울러 채무자를 대위하여 제3채무자에게 이행청구를 하여 채무자에 대하여는 청구인낙을 받고 제3채무자에 대하여 승소판결을 받았는데, 제3채무자가 항소함에 따라 진행된 항소심 절차에서 제3채무자에 대한 소를 취하한 경우에는, 비록 그 자가 대위채권이 없다 하더라도 채무자가 그 대위자격을 인정하여 청구인낙을 한 이상 채무자에게도 재소금지의 효력이 미쳐 채무자는 제3채무자를 상대로 동일한 소를 제기할 수 없다(대법원 1995. 7. 28. 선고 95다18406 판결).

(나) 소송물의 동일

같은 소가 되기 위해서는 전소와 후소의 소송물이 같아야 한다. 따라서 같은 주택인도청구라도 물권인 소유권에 기한 경우와 채권적인 약정에 기한 경우는 같은 소가 아니며(대법원 1991. 1. 15. 선고 90다카25970 판결), 명의신탁해지 후 소유권에 기한 소유권이전등기청구와 명의신탁해지에 의한 신탁관계의 종료만을 이유로 하는 소유권이전등기청구도 별개의 청구이다(대법원 1980. 12. 9. 선고 79다634 전원합의체 판결). 부정경쟁행위 등 같은 행위를 원인으로 제1심에서 청구하지 아니하였던 기간에 해당하는 손해배상청구도 같은 소가 아니다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결). 다만 원본채권의 이행을 청구하는 소 또는 면직처분무효확인 소를 종국판결 후 취하한 후 그 이자채권 또는 면직처분이 무효임을 전제로 한 급여채권에 대한 이행을 청구하는 소를 제기하는 경우와 같이 전소의 소송물이 후소의 소송물에 대한 선결적 법률관계를 이루고 있는 경우에도 재소가 금지된다(대법원

1989. 10. 10. 선고 88다카18023 판결).

(다) 권리보호이익의 동일

재소금지의 취지는 당사자가 권리보호의 이익이 없이 법원의 종국판결을 무용화시켜 농락한 데 대한 제재이기 때문에 당사자에게 소취하 후 재소를 제기할 새로운 권리보호이익이 있는 경우에는 재소가 허용된다. 예컨대 본안판결이 난 다음 피고가 소유권침해를 중지하여 소를 취하하였는데 그 뒤 재침해하는 경우(대법원 1981. 7. 14. 선고 81다64 판결), 피고가 전소취하의 전제조건인 약정사항을 이행하지 않아 약정이 해제·실효되는 사정변경이 있는 경우(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000다46399 판결), 공유지분 양수인이 자신의 권리를 보호하기 위하여 양도인이 취하한 소를 제기한 경우(대법원 1998. 3. 13. 선고 95다48599 판결)에는 재소가 허용된다.

(라) 본안에 대한 종국판결이 선고된 뒤의 취하

본안에 대한 종국판결 후의 소취하이어서야 하므로 소각하판결, 소송종료선언의 판결과 같은 소송판결이 있는 뒤에 소를 취하한 경우에는 재소가 금지되지 않는다. 본안판결인 이상 원고승소판결이든 원고패소판결이든 불문한다. 항소심에서 소를 교환적으로 변경하면 구청구는 종국판결이 선고된 뒤에 소를 취하한 것이 되어 그 뒤 다시 구청구를 제기하는 것은 재소금지에 위반되어 부적법하다(대법원 1987. 11. 10. 선고 87다카1405 판결). 따라서 법원으로서의 항소심에서의 소변경의 경우 그 형태가 교환적인지, 추가적인지 반드시 석명하여야 한다(대법원 1994. 10. 14. 선고 94다10153 판결). 항소심에서 청구취지를 감축하였다가 다시 동일한 청구취지를 확장한 경우에는 재소금지의 원칙에 반한다(대법원 2007. 11. 15. 선고 2007다44156 판결). 다만 원고가 제1심판결선고 전에 지연손해금청구를 일부 취하하였다가 제1심판결선고 후에 다시 같은 소를 제기한 경우에는 재소가 금지되지 아니한다(대법원 2009. 12. 24. 선고 2009다40738 판결).

(3) 효 과

재소금지의 원칙은 공익적 성질을 가지고 있으므로 법원의 직권조사사항이며 재소금지에 어긋나는 소의 제기는 피고가 동의하여도 부적법하므로 각 하하여야 한다. 재소금지는 소송법상의 효과에 그치고 실제법상의 권리관계에는 영향이 없다(대법원 2023. 1. 12. 선고 2022다266874 판결). 따라서 공익법인이 제기한 기본재산에 관한 소송에서 본안에 대한 중국판결이 있는 후소를 취하하였다고 하여 실제법상 권리의 포기라고는 할 수 없으므로 그 소의 취하에 주무관청의 허가를 요하는 것은 아니다(대법원 1989. 7. 11. 선고 87다카2406 판결). 다만 가사소송과 같이 청구를 포기할 수 없는 소송에서는 만일 재소를 금지하면 청구의 포기를 할 수 없는 소송에 대하여 포기를 인정하는 결과가 되기 때문에 재소금지의 효과가 적용되지 않는다.

제30장

소
송
의
종
료

5. 취하서 접수 후의 사무처리

가. 취하서 제출자의 신분확인

취하서는 본인이나 그 포괄승계인이 반드시 직접 제출하여야 하는 것은 아니고, 제3자에 의한 제출도 허용되며, 나아가 상대방에게 소취하서를 교부하여 그로 하여금 제출하게 할 수도 있다(대법원 2001. 10. 26. 선고 2001다37514 판결).

취하서는 소송을 종결시키는 효력이 있는 서류이므로 반드시 접수담당자가 제출자의 신분을 확인하여야 하고(접수예규 2조 1항), 제출자가 작성명의인의 본인이 아닌 경우 작성명의인의 인감증명서가 첨부되어야 하나 소송대리인 등의 경우는 그러하지 아니하다(2조 3항). 한편 전자소송시스템에서 전자문서를 제출하는 경우 전자문서에 전자서명을 하여야 하는데 이 경우 인감의 날인 또는 인감증명서를 첨부하지 아니할 수 있다(민전규 7조 1항, 4항). 이 부분에 대한 자세한 내용은 제6장(접수사무) 참조.

나. 취하서의 전산등록

취하서가 접수되면 문건으로 전산입력하고 즉시 재판장의 확인결재를 받아야 하며, 그 소의 취하가 적법하여 취하의 효력이 발생하면 재판사무시스템의 종국결과 입력화면에 종결사유를 '소취하'로 표시하고 취하서 접수일자 및 효력 발생일을 기재한다. 이때 피고가 본안에 관하여 준비서면을 제출하여 소취하에 피고의 동의를 받아야 하는 경우에는 취하서 접수일자와 취하의 효력 발생일이 달라질 수 있다.

다. 송 달

소장이 송달된 후 소를 취하한 경우에 서면에 의한 취하이면 취하서의 부분을, 말로 취하한 때에는 그 기일의 조서등본을 상대방에게 송달하여야 한다(민소 266조 4항, 5항). 그러나 취하서에 상대방의 동의 의사가 인감증명 등에 의하여 명백하게 표시된 때 또는 취하한 그 기일에 상대방이 출석한 경우에는 송달할 필요가 없다.

라. 기 타

소취하의 존재 여부 또는 유·무효에 관하여 다툼이 있으면 당사자는 기일 지정신청을 할 수 있고, 이 신청이 있으면 법원은 변론을 열어 처리하여야 한다는 것은 전술한 바와 같다.

제4절 소송상 화해

1. 총 설

‘소송상 화해’라 함은 소송의 계속 중에 수소법원·수명법관 또는 수탁판사 앞에서 당사자가 소송물인 권리 또는 법률관계에 관하여 상호 그 주장을

양보함에 의하여 다툼을 해결하는 소송상 합의를 말한다. 화해가 성립되어 당사자 쌍방의 일치된 진술을 조서에 기재한 때에는 확정판결과 동일한 효력이 있으므로(민소 220조), 화해가 이루어진 소송물 범위 내에서 소송은 당연히 종료한다.

당사자가 소송 외에서 행하는 합의·타협 등은 사법상의 화해계약(민법 731조)에 불과하여 그에 의하여 직접 소송종료의 효과가 생기는 것은 아니므로 소송상 화해는 아니다.

소송상 화해는 소송제기 전에 지방법원 또는 시·군법원에 화해를 신청하여 해결하는 제소전화해(민소 385조 내지 389조, 법조 34조 1항 2호)와 더불어 재판상 화해라 불리는데, 그 성립의 시기나 처리방식에서 차이가 있으나 성질과 효력은 동일하다. 제소전화해에 대하여는 제36장(제소전화해)에서 자세히 설명하기로 하고, 여기서는 소송상 화해에 관하여 살펴본다.

2. 요건

가. 당사자

당사자는 소송능력이 있어야 하며, 대리인에 의한 화해에는 특별한 권한을 받아야 한다(민소 56조 2항, 90조 2항). 필수적 공동소송에서는 공동소송인 전원이 일치하여 화해하여야 한다(67조 1항). 화해는 양쪽 당사자 사이에 성립하는 것이 일반적이나, 제3자도 소송절차에 참가하여 화해할 수 있다(대법원 1985. 11. 26. 선고 84다카1880 판결).

나. 소송물

(1) 화해의 대상인 권리관계가 사적 이익에 관한 것이고 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 것이어야 한다. 직권탐지주의가 적용되는 사건에서는 권리나 법률관계를 임의로 처분할 수 있는 이혼사건이나 파양사건 등에서만 예외적으로 허용된다. 주주총회결의의 부존재·무효를 확인하거나 결의를 취소

하는 판결이 확정되면 당사자 이외의 제3자에게도 그 효력이 미쳐 제3자도 이를 다룰 수 없게 되므로, 주주총회결의의 하자를 다투는 소에서 그 결의의 부존재·무효를 확인하는 내용의 화해는 할 수 없으나(대법원 2004. 9. 24. 선고 2004다28047 판결), 원고패소판결은 당사자 사이에서만 효력이 있으므로 청구의 포기를 내용으로 하는 화해는 허용되며, 주주대표소송에서 소송상 화해를 함에는 법원의 허가를 받아야 한다(상법 403조 6항). 증권관련 집단소송에서의 소송상 화해 역시 법원의 허가를 받아야 한다(증집 35조 1항).

(2) 제소전화해가 인정되므로, 소송요건의 흠이 있는 소송물이라도 원칙적으로 화해가 허용된다. 이 점에서 청구의 포기·인낙과 다르다.

(3) 화해의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서나 강행법규에 반하여서는 안 되는지 여부에 관하여, 판례는 화해의 내용이 강행법규에 위반하거나(대법원 1975. 3. 11. 선고 74다2030 판결), 화해에 이르게 된 동기나 경위에 반윤리적·반사회적인 요소가 있더라도 화해가 무효라는 주장을 할 수 없다고 한다(대법원 1999. 10. 8. 선고 98다38760 판결). 화해조항의 강행법규 내지 공서양속 위반은 재심사유에 해당될 흠이 있는 경우를 제외하고는 준재심사유가 되지 않으므로, 화해조항이 강행법규 내지 공서양속에 위반하지 않도록 특히 주의하여야 한다.

(4) 소송상 화해에서 그 내용을 이루는 이행의무의 발생에 조건을 붙일 수 있다. 일정한 조건(예컨대 제3자의 이의)이 성취되면 화해가 실효되기로 합의한 실효조건부화해에 대하여, 판례는 실효조건의 성취로 그 화해의 효력은 당연히 소멸된다고 보고 있다(대법원 1993. 6. 29. 선고 92다56056 판결).

다. 상호의 양보

소송상 화해의 요건인 양보의 방법 또는 범위에 관하여는 대단히 넓게 해석하는 것이 실무이다. 즉 당사자가 화해에서 양보의 방법으로서 제쟁물에 관계없는 물건 또는 금전의 지급을 약속하거나 제3자와의 권리관계를 포함

시켜도 되고, 소송물의 전부를 인정 또는 포기하더라도 소송비용의 부담에 관하여만 양보할 수도 있으며, 피고가 채무를 전부 인정하고 원고가 기한의 유예를 주는 경우도 있다. 결국 소송상 화해에는 원고의 양보(일부 포기)가 포함되어야 하므로 후술하는 화해조항에는 “원고는 나머지 청구를 포기한다.”라는 조항이 일반적으로 기재된다.

3. 절 차

가. 시 기

소송계속 중이면 어느 때나 화해가 가능하고, 항소심·상고심에서도 화해할 수 있다. 변론종결 후 혹은 판결이 선고되어 그 정본이 송달된 이후라도 아직 확정 전이라면 소송상 화해를 위한 화해기일지정신청을 한 뒤에 지정된 기일에서 화해할 수 있다. 법원은 소송 정도에 관계없이 화해를 권고하거나 수명법관 또는 수탁판사로 하여금 권고하게 할 수 있고(민소 145조 1항), 나아가 화해권고결정도 할 수 있다(225조). 소송대리인이 선임된 사건에서는 법원은 화해를 위하여 당사자 본인이나 법정대리인의 출석을 명할 수 있다(145조 2항).

보전소송절차가 계속 중인 법원에서 당해 절차에 관하여 화해할 수 있음은 물론이다. 나아가 본안에 관하여도 화해할 수 있는지에 관하여 이를 부정한 판례가 있으나(대법원 1958. 4. 3. 자 4290민재항121 결정) 위 판례는 화해의 성질을 소송행위설로 변경하기 이전의 판례이고, 보전절차에서 본안의 청구에 관하여도 화해할 수 있다고 보는 것이 실무이다.

나. 방 식

화해는 기일에 화해 당사자가 출석하여 말로 진술하는 것이 원칙이다(구술화해). 기일이면 변론기일·변론준비기일·화해기일뿐만 아니라 증거조사기일이라도 무방하다.

민사소송법은 서면화해제도를 채택하여, 당사자가 변론기일 또는 변론준비기일에 출석하지 않은 경우에도 당사자가 진술한 것으로 보는 답변서·준비서면에 화해의 의사표시가 적혀 있고 공증사무소의 인증을 받은 경우에 상대방 당사자가 기일에 출석하여 그 화해의 의사표시를 받아들인 때에는 소송상 화해가 성립된 것으로 본다(민소 148조 3항, 286조). 공증사무소의 인증을 받지 아니하였거나 그 의사표시가 불분명한 경우에는 화해권고결정제도를 활용함으로써 화해적 해결의 의사표시를 한 취지를 살릴 수 있을 것이다.

4. 구체적 운영방법

소송상 화해는 법관 앞에서 당사자가 상호 절충하고 법관이 알선·중개하는 방법을 취하거나, 법관이 개별적으로 당사자 일방을 면담하여 그 의견이나 희망 등을 청취하여 이를 상대방에게 전달하면서 아울러 절충을 도모하거나 또는 당사자 쌍방이 스스로 합의에 도달하여 실제법상의 권리관계를 확정된 후 법관 앞에서 합의의 내용을 진술하여 그 결과를 법원사무관등이 조서에 기재하여 명확히 하는 방법 등이 있다. 어느 경우에도 소송상 화해는 특별수권사항이고(민소 56조 2항, 90조 2항), 그 권한은 서면으로 증명하여야 하므로(58조, 89조), 법정대리인 또는 소송대리인이 화해를 할 경우에는 소송기록에 의하여 이러한 서면의 유무를 사전에 조사하여야 한다.

전술한 바와 같이 소송의 당사자가 아닌 제3자의 권리관계도 화해의 대상이 될 수 있는데, 이 경우에 그 제3자가 직접 화해의 당사자로 화해절차에 참가하는 방식과 직접 당사자가 되지는 아니하고 단지 수익자로서 화해의 내용에 포함됨에 그치는 방식의 2가지 종류가 있다. 전자의 경우에는 그 제3자 또는 당사자가 단독으로 혹은 공동하여 화해에 참가시켜 줄 것을 법원에 신청하게 되는데, 법원은 이 신청에 따라 제3자를 출석시켜 소송당사자와 사이에 화해를 권고할 것이나(민소 145조), 실무에서는 소송당사자와 제3

자 사이에 미리 합의가 이루어져서 함께 법원에 출석하는 것이 보통이므로, 이때에는 말에 의한 제소전화해 신청으로 보아 조서에 그 취지를 기재하고 인지를 붙이면 될 것이다.

5. 화해성립 후의 법원사무관등의 사무처리

가. 변론(준비기일)조서 작성의 특례

변론기일이나 변론준비기일에 사실의 주장 또는 증인신문이 행하여진 후에 소송상 화해가 성립된 경우 등과 같이 소송이 판결에 의하지 아니하고 완결될 때에는 재판장의 허가를 받아 증인·당사자 본인 및 감정인의 진술과 검증결과의 기재를 생략할 수 있다(민소규 32조 1항). 법원사무관등은 재판장의 허가가 있는 때에는 바로 그 취지를 당사자에게 통지하여야 한다(2항). 당사자가 위 통지를 받은 날부터 1주 안에 이의를 한 때에는 법원사무관등은 바로 그 증인·당사자 본인 및 감정인의 진술과 검증결과를 적은 조서를 작성하여야 한다(3항).

제30장

소
송
의
종
료

나. 화해조서의 작성

(1) 개 설

소송상 화해가 성립된 경우에는 법원 또는 법관은 그 요건을 심사하여 유효하다고 인정되면 법원사무관등에게 그 내용을 조서에 기재시킨다(민소 154조 1호). 변론(준비)기일에 소송상 화해가 성립된 경우에는 화해조서는 변론(준비기일)조서의 일부로 작성된다. 이때 기본조서에는 “당사자 별지조서와 같이 화해”라고 기재하고 법원사무관등 및 재판장이 기명날인한 후, 법원사무관등이 화해조서(구술화해의 경우 [전산양식 A1690], 서면화해의 경우 [전산양식 A1691])와 간인한다. 특히 화해만을 위한 기일에 화해가 성립한 경우에는 기본조서로서의 기일조서[전산양식 A1662]와 화해조서를 작성한다(민소규 31조).

조서 말미에는 재판장과 법원사무관등이 기명날인한다(민소 153조).

(2) 형식적 기재사항

화해조서의 형식적 기재사항은 ‘사건과 당사자의 이름을 부름’이라는 글귀를 기재하지 아니하는 것과 ‘고지된 다음 기일’란이 없다는 것을 제외하고는 변론조서의 경우와 동일하다. 화해에 당사자 이외의 제3자가 참가한 경우에는 출석상황란에 그 출석을 기재한다. 이 경우 그 제3자의 호칭으로 ‘화해참가인’으로 기재하는 것이 적당하다.

상소심에서 화해가 된 경우에는 조서에 사건번호를 기재함에 있어 원심법원 및 사건번호를 병기하며, 재심절차에서 화해가 된 경우에는 재심의 대상이 된 사건의 법원 및 사건번호를 병기한다(재민 90-1 상소심에서의 화해조서 등에 원심법원 및 원심사건번호의 기재).

[조서기재례]

① 상소심에서 화해가 된 경우

사 건 2025나101 소유권이전등기
(원심사건 ○○지방법원 2024가합111)

② 재심절차에서 화해가 된 경우

사 건 2025재나101 소유권이전등기
(확정사건 ○○고등법원 2024나111)

(3) 실질적 기재사항

화해조서의 실질적 기재사항으로서는 (가) 화해성립사실 (나) 청구의 표시 (다) 화해조항의 3가지가 있고 그 기재 순서도 위와 같다.

화해성립사실과 화해조항은 조서의 필수적 기재사항이고(민소 154조 1호), 화해조서에 당사자와 청구의 표시를 하게 하는 것은 화해조서가 확정판결과 동일한 효력이 있으므로 조서의 기재로써 화해의 효력이 미치는 주관적·객관적 범위를 명확히 하여 둘 필요가 있기 때문이다.

(가) 화해성립사실

조서의 요지란의 첫머리에 “위 당사자는 다음과 같이 화해하였다.”라고 기

재한다.

공동소송에 있어 그 일부 당사자 사이에 화해가 성립된 경우에는 “원고와 피고 ○○○는 다음과 같이 화해하였다.”라고 기재하고, 제3자가 참가한 경우에는 “위 당사자 및 화해참가인은 다음과 같이 화해하였다.”라고 기재한다.

(나) 청구의 표시

청구의 표시는 ‘청구취지’와 ‘청구원인’으로 나누어 기재한다[전산양식 A1690].

소송의 계속 중에 소의 변경, 소의 일부 취하도 있을 수 있고 또 청구의 일부에 관하여만 화해가 성립될 수도 있으므로(이 경우에는 화해가 성립된 부분의 청구만을 기재하여야 한다), 소장(또는 청구취지·청구원인을 그대로 옮겨 써서는 안 되며 화해성립시에 원고가 유지하고 있는 청구 또는 화해의 대상이 된 권리 또는 법률관계에 관하여 청구취지와 청구원인을 간결하게 정리하여 기재한다. 청구취지나 청구원인이 결국 소장이나 준비서면의 기재와 같게 된다 할지라도 “소장(또는 2025. 1. 16. 자 준비서면) 기재와 같다.”라는 식으로 인용하여서는 아니 된다.

다만 소액사건에서는 특히 필요하다고 인정되는 경우 외에는 청구의 원인을 적지 아니한다(민소규 31조).

① 청구취지

청구취지는 판결문의 청구취지나 주문의 기재와 대체로 동일하다. 이에 대한 자세한 설명은 제16장(소의 제기) 참조.

② 청구원인

청구원인에 대한 자세한 설명은 제16장(소의 제기) 참조.

③ 소송물 이외의 권리 또는 법률관계가 부가된 경우

소송물 이외의 권리관계를 부가한 경우에는 그 권리관계에 관하여도 이를 특정하여 표시하여야 한다.

소송물 이외의 권리관계를 부가하여 화해가 성립된 경우에 있어 부가된 청구의 표시에 관하여는 2가지의 방법이 있다.

그 하나는 본래의 청구의 표시 다음에 '위 이외에 화해의 대상이 된 권리관계'라고 한 후 부가된 청구를 특정하여 기재하는 방법이고, 나머지 하나는 화해조항 중에 기재하는 방법으로서, 예컨대 “피고는 원고에게 본소 청구 ○○원 및 원고가 피고에게 2025. 9. 5. 매도한 책상 1개 대금 ○○원 합계 ○○원을 2025. 12. 31.까지 지급한다.”라고 기재하는 방식이다.

피고가 자기의 권리관계를 덧붙인 경우라든가 제3자가 참가하여 그의 권리관계가 부가된 경우에는 달리 청구의 표시를 할 필요가 없고 화해조항 중에서 특정하면 충분하다. 예컨대 원고가 임대차 종료에 의한 건물인도를 구하는 사건에서 건물인도에 관한 화해에 관련하여 피고가 목적물에 지출한 유익비의 상환을 청구하여 원고와 사이에 이 점에 관하여도 합의가 이루어졌다면, 화해조항 중에 “원고는 피고에게 피고가 이 사건 건물의 대문을 새 것으로 갈아 끼운 비용 ○○원을 2025. 5. 15.까지 지급한다.”라고 기재하면 충분하다. 소송대리인이 이와 같이 원래의 소송물 이외의 권리관계에 관하여 화해를 하는 경우에는 소송대리권의 범위는 원래의 소송물에만 미친다 할 것이므로 이 점에 관한 특별한 권한을 받아야 할 것이다.

(다) 화해조항

이 부분에 대하여는 제39장(민사조정절차) 제5절 참조.

[화해조서 기재례]

○ ○ 지 방 법 원

제 ○ 민사부

화 해 조 서

사 건 2024가합101 건물인도등

원 고 ○ ○ ○

서울 중구 ○○로 ...

피 고 ○ ○ ○

서울 서초구 ○○로 ...

재판장 판사 ○ ○ ○ 기 일 2025. 6. 20. 10 : 00

판사 ○ ○ ○ 장 소 제105호 법정

판사 ○ ○ ○ 공개여부 공개

법원사무관 ○ ○ ○

원고 대리인 ○ ○ ○

출석

피고 대리인 ○ ○ ○

출석

위 당사자는 다음과 같이 화해하였다.

청구의 표시

청구취지 :

피고는 원고에게 서울 서초구 서초동 ○○○ 지상 시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 120㎡를 인도하고, 2024. 3. 30.부터 인도 완료시까지 월 300,000원의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

청구원인 :

원고는 2023. 12. 30. 피고에게 청구취지 기재의 건물을 기간 1년, 차임 월 300,000원을 매월 말일에 지급받기로 약정하고 임대하였는데, 피고가 2024. 3. 30. 이후 차임을 지급하지 아니하므로 원고는 2024. 7. 10. 피고에게 위 임대차계약을 해지한다는 의사표시를 내용증명으로 발송하여 그다음 날 피고에게 도달하였다.

위 임대차계약은 종료되었으므로 원고는 위 건물의 인도와 함께 2024. 3. 30.부터 인도 완료시까지 월 300,000원의 비율에 의한 차임 및 차임 상당 손해금의 지급을 구한다.

화 해 조 항

1. 피고는 원고에게 서울 서초구 서초동 ○○○ 지상 시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 120㎡를 2025. 9. 30.까지 인도한다.
2. 피고는 원고에게 2025. 8. 31.까지 1,800,000원을 지급하고, 2025. 9. 1.부터 인도 완료시까지 월 300,000원의 비율에 의한 금원을 지급한다.
3. 원고는 나머지 청구를 포기한다.
4. 소송비용은 각자 부담으로 한다.

법원사무관 ○ ○ ○

재판장 판사 ○ ○ ○

제30장

소
송
의
종
료

다. 화해조서의 정본 송달

화해조서는 신청이 없더라도 화해가 있는 날부터 1주 안에 그 조서의 정본을 당사자에게 송달하여야 한다(민소규 56조). 화해에 제3자가 참가한 경우에는 그에게도 송달하여야 할 것이다.

라. 인지액의 환급

제1심 또는 항소심에서 소송상 화해가 있는 때(민소 231조에 의하여 소송상 화해와 동일한 효력이 있는 경우를 포함한다)에는 소제기 당시 납부한 인지액의 2분의 1에 해당하는 금액의 환급을 청구할 수 있다(인지 14조 1항 5호). 그 자세한 절차는 제6장(접수사무) 참조.

6. 화해성립의 효과

가. 개 설

소송상 화해의 진술을 조서에 적은 때에는 그 조서는 확정판결과 같은 효력이 있다(민소 220조). 따라서 그에 의하여 소송은 종료됨과 동시에 그 화해조서를 집행권원으로 하여 강제집행을 할 수 있다(민집 56조). 상급심에서 화해가 된 때에는 하급심의 미확정 판결은 당연히 실효된다. 소송상 화해의 경우 소송비용에 대하여 특별히 정한 바가 없으면 각자 지출한 비용을 부담한다(민소 106조).

재판상 화해의 창설적 효력이 미치는 범위는 당사자가 서로 양보하여 확정하기로 합의한 사항에 한하며, 당사자가 서로 다툼 사실이 없었던 사항은 물론 화해의 전제로서 서로 양해하고 있는 데 지나지 않은 사항에 관하여는 미치지 아니한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 99다17319 판결). 한편 재판상 화해에서 법원에 계속 중인 다른 소송을 취하하기로 하는 내용의 화해조서가 작성된 경우 다른 소송이 계속 중인 법원에 취하서를 제출하지 않는 이상 그 소송이 취하로 종결되지는 않지만 그 소송의 원고에게는 권리보호의 이

익이 없게 되어 그 소는 각하되어야 한다(대법원 2005. 6. 10. 선고 2005다14861 판결).

나. 효력을 다투는 방법

(1) 화해조서에 분명한 잘못이 있을 때에는 판결에 준하여 경정이 허용된다(민소 211조). 화해조서의 경정 방법 및 당사자에 대한 송달은 판결경정에 준하여 처리하면 된다.

화해조서에 기재된 내용이 특정되지 아니하여 강제집행을 할 수 없는 경우에는 동일한 청구를 제기할 소의 이익이 있다(대법원 1995. 5. 12. 선고 94다25216 판결). 제1화해가 성립된 후에 그와 모순된 제2화해가 성립되어도 제1화해가 조서에 기재되어 확정판결과 동일하게 기판력이 발생한 이상 제2화해에 의하여 제1화해가 당연히 실효되거나 변경된다고 할 수 없다(대법원 1995. 12. 5. 선고 94다59028 판결).

(2) 판례에 의하면, 소송상 화해는 기판력이 있으므로 확정판결의 무효사유와 같은 사유가 있을 때를 제외하고는(대법원 1990. 3. 17. 자 90그3 결정), 재심사유에 해당될 흠이 있는 경우에 한하여 준재심(민소 461조)의 소로 다투는 방법 이외에는 그 무효를 주장할 수 없다(대법원 1999. 10. 8. 선고 98다38760 판결). 당사자가 소송상 화해의 당연무효를 주장하면서 기일지정신청을 한 때에는, 법원은 변론기일을 열어 당연무효사유가 있는지를 심리한 다음 무효사유가 존재한다고 판단된다면 심리를 속행하고, 그 사유가 존재하지 아니하면 판결로써 소송종료선언을 하여야 한다(대법원 2000. 3. 10. 선고 99다67703 판결).

제30장

소
송
의
종
료

7. 화해권고결정

가. 의 의

법원·수명법관 또는 수탁판사는 소송에 계속 중인 사건에 대하여 직권으

로 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 청구의 취지에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 사건의 공평한 해결을 위한 화해권고결정을 할 수 있다(민소 225조). 민사소송법은 화해권고안의 권위와 공정성에 믿음을 주고, 화해를 성공적으로 이끌 수 있도록 하기 위하여 직권으로 화해권고결정을 하고 당사자가 이의 없이 받아들이면 소송상 화해가 성립되는 제도를 마련한 것이다.

나. 화해권고결정과 수소법원 조정제도의 관계

화해권고결정과 조정을 갈음하는 결정(수소법원 조정)은, 그 제도적 기초는 소송절차와 비송절차로 분명하게 구분되지만, 소송사건의 심리과정에서 출발하여 법원이 직권에 의하여 결정이라는 재판의 형식으로 화해안을 제시하고 일정기간 안에 당사자의 이의가 없으면 확정판결과 동일한 효력을 가지게 된다는 점에서는 대단히 유사하다. 그러나 구체적으로 살펴보면 다음과 같은 차이점이 있으므로, 실무에서 양 제도를 운영하면서 유의하여야 한다.

① 절차의 면에서 보면, 화해권고결정은 소송절차의 진행 도중이면 판결 선고 시까지 사이에 언제라도 할 수 있지만, 조정을 갈음하는 결정은 수소법원의 이름으로 먼저 조정회부결정을 하여 소송절차를 중지시킨 이후라야 할 수 있다는 점에 차이가 있다. 또한 화해권고결정은 기일을 정하지 않고도 할 수 있으나, 조정을 갈음하는 결정은 반드시 조정기일을 정하여 당사자 사이에 조정을 시도해 본 다음 조정이 불성립되거나 당사자가 불출석하였을 때 비로소 할 수 있다는 점에서 다르다.

② 주체의 측면에서 보면, 화해권고결정이나 수소법원 조정 모두 수소법원이나 수명법관이 할 수 있는 것은 같다. 다만 화해권고결정은 변론준비절차에서 재판장도 할 수 있으나, 수소법원 조정은 재판장의 자격으로는 할 수 없고 수명법관으로 지정되어야만 할 수 있다. 수소법원 조정은 조정위원회가 처리할 수 있으나, 화해권고결정은 위원회 방식으로는 처리할 수 없다.

③ 반드시 양쪽 당사자의 양보가 필요한지에 관하여 보면, 소송상 화해는 상호 양보를 전제로 하고 있으므로 화해권고결정도 양쪽 모두의 양보가 필요하다 볼 수 있지만, 여기서의 양보는 소송비용부담 부분에 대한 양보만으로도 가능하다. 이에 비하여 수소법원 조정은 당사자의 상호 양해를 통하여 조리를 바탕으로 실정에 맞게 분쟁을 해결하는 제도이므로 조리에 맞는 해결책이라고 보이면 원고의 청구를 전부 받아들이거나 전부 배척하는 조정도 가능하다.

④ 화해권고결정에서는 소송물 이외의 사항을 대상으로 삼을 수 있는지 여부 및 피고의 반소가 없는 경우에 원고에게 이행을 명하는 화해권고결정을 할 수 있는지 여부에 대하여 견해가 대립된다. 판례는 화해권고를 위하여 필요한 경우에는 소송물 아닌 권리 내지 법률관계를 그 대상에 포함시킬 수 있고, 이 경우 화해권고결정의 효력은 그 내용에 따라 그 결정에 기재된 당사자에게 미친다고 한다(대법원 2008. 2. 1. 선고 2005다42880 판결).

반면 수소법원 조정에서는 아직 분쟁의 대상으로 되지 아니한 다른 권리관계나 다른 곳에서 계속 중인 소송의 소송물 등도 조정의 대상으로 삼을 수 있다는 점에 관하여 이론이 없고, 또한 수소법원 조정에서는 조정절차의 진행과정으로 보아 원고로 하여금 반대급부를 피고에게 이행하도록 하는 조정안이 전혀 예상 외의 것이 아니라면 피고의 별도의 청구가 없어도 원고로 하여금 피고에게 이행하도록 하는 내용의 조정을 갈음하는 결정을 할 수 있다고 본다.

⑤ 제3자의 참여에 관하여 보면, 화해권고결정에는 결정의 효력이 제3자에게도 미치는 제3자의 강제참가제도가 없다. 그러나 수소법원 조정에는 이해관계인을 강제로 조정절차에 참가시킬 수 있고(민조 16조), 당사자와 참가인 사이에 조정이 성립되거나 조정을 갈음하는 결정이 확정되면 참가인에게도 그 효력이 미친다.

⑥ 소송절차에서의 원용 제한에 관하여 보면, 화해권고결정은 그 과정에

있었던 당사자의 진술을 다시 소송절차에서 원용하는 데 제한이 없으나, 조정절차에서의 당사자 또는 이해관계인의 진술은 소송절차에서 원용하지 못한다(민조 23조).

다. 화해권고결정의 운영

(1) 주 체

화해권고결정은 수소법원·수명법관 또는 수탁판사가 할 수 있다(민소 225조). 변론준비절차에도 화해권고결정에 관한 규정이 준용되므로(286조), 그 변론준비절차를 진행하는 재판장 등이 그 이름으로 화해권고결정을 할 수 있다. 또한, 변론준비절차에 부쳐진 뒤에도 수소법원은 여전히 화해권고결정을 할 수 있다. 보전처분 절차에서도 화해권고결정을 할 수 있으나, 보전처분 절차에서 이루어진 화해권고결정은 가압류·가처분과 달리 화해권고결정正本에 집행문을 받아야 강제집행을 할 수 있다(대법원 2022. 9. 29. 자 2022마5873 결정).

(2) 시 기

법원은 소송의 정도와 관계없이 화해를 권고할 수 있고(민소 145조), 소송 계속 후 판결선고 전까지 언제라도 별도의 기일지정이나 조정회부 없이 화해권고결정을 할 수 있다(225조). 따라서 변론절차에서는 물론 변론준비절차에서도 할 수 있다(286조). 실제로는 변론준비절차를 거쳐 쟁점이 정리된 후 양쪽 당사자가 소송의 승패에 대하여 어느 정도 예측을 할 수 있게 되는 단계에서 하는 것이 바람직하다.

(3) 적합한 사건의 유형

화해권고결정은 수소법원 조정제도에 비하여 절차가 유연하고 탄력적이어서 많이 활용될 필요가 있는데, 특히 아래 사건들이 화해권고결정에 적합하다고 할 수 있다.

- ① 법원의 화해안에 대하여 경미한 부분의 의견차이로 화해가 성립되지

않는 경우

② 감정적인 문제로 어느 일방도 먼저 화해안을 수락하는 모습을 보이고 싶지 않아 하는 경우

③ 사건의 성격상 결론에 이르는 과정이나 법원의 제안 내용을 세밀하게 따져 보아야 하기 때문에 법정에서 곧바로 수락 여부를 결정할 것을 기대하기는 어렵지만, 법원의 판단을 표명하기만 하면 되고 따로 조정에 회부하여 절충을 할 필요는 별로 없는 사건(대표적으로 손해배상청구 사건)

④ 서면에 의한 화해(민소 148조 3항), 서면에 의한 청구의 포기나 인낙(148조 2항)에서 공증이 누락되거나 화해, 청구의 포기나 인낙의 의사표시가 불명확한 경우

제30장

소송의
종료

(4) 범위와 절차

화해권고결정은 '청구의 취지에 어긋나지 아니하는 범위 안에서' 하는 것인데, 그 의미는 원고가 주장하는 것보다 더 유리한 결정을 하여서는 안 된다는 것과 원고가 전혀 예상하지 못하는 내용의 결정을 하여서는 안 된다는 것으로 해석된다.

화해권고결정은 직권에 의하여 이루어지므로 당사자의 화해권고결정 신청은 법원의 직권발동을 촉구하는 의미만 있다. 결정에 앞서 임의적인 화해가 이루어질 수 있도록 권유하는 것이 보통이겠지만, '사전에 화해를 권유하였으나 화해가 성립되지 아니하였을 것'이 화해권고결정을 할 수 있는 요건은 아니다.

(5) 결정서 및 결정조서의 작성과 송달

(가) 보통은 화해권고결정서[전산양식 A1970]를 작성하는 방법에 의하여 할 것이나 변론준비기일 또는 변론기일에 말로 결정의 내용을 먼저 고지하고, 결정의 내용을 적은 화해권고결정조서[전산양식 A1971]를 작성해도 된다. 결정서를 작성하는 경우에는 화해권고 결정사항 외에 청구의 취지와 원인을 적어야 하고, 조서에 기재하는 경우에는 기일조서에는 화해권고결정을 하였

다는 취지만을 적고 별도의 화해권고결정조서에 민사소송법 153조의 형식적 기재사항과 화해권고결정사항 및 청구의 취지와 원인을 적어야 한다(민소규 57조, 31조). 다만 이 청구취지와 청구원인은 소송물을 특정할 수 있는 정도로 적으면 충분하다. 그러나 소액사건심판법 2조 1항의 소액사건에서는 특히 필요하다고 인정하는 경우 외에는 청구의 원인을 적지 아니한다(민소규 57조 1항 단서).

또한 실무상으로는 청구취지와 청구원인을 구체적으로 기재하는 대신 “청구의 표시: 별지와 같다.”라는 식으로 적고 소장을 복사하여 첨부하기도 한다. 다만 청구의 취지나 원인이 변경된 경우 또는 변론기일에서 일부 취하가 있었던 경우 등에는 소장 사본을 그대로 별지로 사용하지 않도록 유의하여야 한다.

(4) 법원사무관등은 화해권고결정의 내용을 기재한 결정서 또는 조서의 정본을 당사자에게 송달하여야 한다. 기일에 당사자에게 결정내용을 고지한 경우에도 이를 송달하여야 한다(민소 225조 2항 본문). 화해권고결정의 내용을 기재한 결정서 또는 조서의 정본을 송달하는 때에는 그 결정서 또는 조서를 송달받은 날부터 2주 안에 이의를 신청하지 아니하면 화해권고결정이 재판상 화해와 같은 효력을 가지게 된다는 취지를 당사자에게 고지하여야 하는데(민소규 58조), 실무상 별도의 안내서를 작성하지 않고 결정서 또는 결정조서의 끝 부분에 위와 같은 취지의 안내 문구를 적어 고지하고 있다.

다만 결정서 또는 결정조서의 정본은 발송송달이나 공시송달의 방법으로 송달할 수 없으므로(민소 225조 2항 단서), 발송송달 또는 공시송달의 방법에 의하지 않고는 송달할 수 없는 때에는 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 따라 화해권고결정을 취소하여야 한다(민소규 59조 1항). 화해권고결정을 취소하는 결정은 당사자에게 적당한 방법으로 고지하면 된다. 보통은 화해권고 결정취소결정(전산양식 A1973)을 작성하여 이를 송달하는 방법으로 하지만, 다음 기일이 열렸을 때 화해권고결정이 취소되었음을 고지하고 조서에 그

취지를 기재하는 방법으로 처리할 수도 있다.

(다) 화해권고결정을 취소하면 화해권고결정은 그 효력을 잃게 되므로, 그 후에 당사자가 원하는 등 다시 화해권고결정을 할 필요가 있는 경우에는 새로운 결정을 하고 송달을 하여야 한다. 화해권고결정이 취소된 경우에 소송은 화해권고결정 이전의 상태로 돌아가게 되며, 이 경우 그 이전에 행한 소송행위는 그대로 효력을 가지게 된다(민소규 59조 2항, 민소 232조 1항).

라. 화해권고결정에 대한 이의신청

(1) 이의신청의 처리

(가) 당사자는 결정서 또는 결정조서의 정본을 송달받은 날부터 2주 이내에 이의신청을 함으로써 화해권고결정에 대하여 불복할 수 있고, 그 정본을 송달받기 전에도 이의신청할 수 있다(민소 226조 1항). 2주의 기간은 소송행위의 추후보완이 가능한 불변기간이다(2항).

(나) 이의신청은 당사자와 법정대리인, 화해권고결정의 표시와 그에 대한 이의신청의 취지를 적은 이의신청서를 화해권고결정을 한 법원에 제출하는 방법으로 하여야 하므로(민소 227조 1항, 2항), 변론준비기일 등에서 말로 하는 이의신청은 그 효력이 없다. 이의신청서에 기재하도록 요구하고 있는 화해권고결정의 표시와 그에 대한 이의신청의 취지는 제출된 서면을 전체적으로 보아 어떠한 화해권고결정에 대하여 이의를 한다는 취지가 나타나면 족하고, 그 서면의 표제가 준비서면 등 다른 명칭을 사용하고 있다고 하여 달리 볼 것은 아니다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2010다5694 판결).

(다) 이의신청서가 접수되면 법원사무관등은 이의신청기간의 도과 여부 등을 검토하여 재판장에게 기록과 함께 인계한다. 그 이의신청이 방식에 어긋나거나 이의신청권이 소멸한 뒤의 것으로서 그 흠을 보정할 수 없으면 법원은 결정으로 이를 각하하며, 이 결정에 대해서는 즉시항고할 수 있다(민소 230조).

(라) 적법한 이의신청이 있으면 법원사무관등은 상대방에게 그 부분을 송달하여야 한다(민소 227조 4항). 이는 화해권고결정에 대하여 이의신청이 있음을 알리고 다음 소송행위를 준비하게 하기 위한 것이다. 실무상 재판장은 이의신청서가 제출되면 그 사건의 다음 심리단계의 기일을 지정하고, 기일통지서와 함께 이의신청서 부분을 송달하게 하는 방법으로 운영할 수 있을 것이다.

(마) 적법한 이의신청이 있으면 소송은 화해권고결정이 있기 전의 상태로 되돌아간다. 이 경우 소송복귀를 위한 특별한 조치가 필요 없고, 그 이전에 행한 소송행위는 모두 그대로 효력을 가지게 된다(민소 232조 1항). 이의신청에 의하여 소송절차가 계속되더라도 당연히 화해권고결정의 효력이 없어지는 것은 아니고, 그 심급에서 판결이 선고될 때까지는 화해권고결정의 효력이 유지됨으로써(2항), 그 전에 이의신청이 취하되면 화해권고결정이 확정된다(228조 1항, 231조).

(바) 독립당사자참가인이 화해권고결정에 대하여 이의한 경우, 합일확정의 필요상 이의의 효력은 원·피고 사이에도 미친다(대법원 2005. 5. 26. 선고 2004다25901 판결). 그러나 통상공동소송관계에 있는 원고 중 1인만이 화해권고결정에 대하여 이의한 경우 이의하지 아니한 다른 원고와 피고 사이에서 그 화해권고결정은 확정된다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다53754 판결).

(2) 이의신청의 취하와 포기

(가) 화해권고결정에 대하여 이의신청을 한 당사자는 그 심급에서 판결이 선고될 때까지 상대방의 동의를 얻어 이의신청을 취하할 수 있다(민소 228조 1항). 이의신청의 취하는 서면으로 하여야 하나, 다만 변론(준비)기일에는 말로 할 수 있다(2항, 266조 3항). 취하의 서면은 상대방에게 송달하여야 하고, 취하의 취지를 기재한 조서등본은 그 진술을 한 기일에 상대방이 출석하지 아니한 경우에 송달한다(228조 2항, 266조 4항, 5항). 취하의 서면이나 그러한 취지가 기재된 조서등본을 상대방에게 송달한 날 또는 이의신청을 취하

한 기일에 상대방이 출석한 때에는 그 기일부터 2주 이내에 상대방이 이의를 하지 아니하면 이의신청취하에 동의한 것으로 본다(6항). 이의신청이 적법하게 취하되면 화해권고결정은 재판상 화해와 같은 효력을 가지게 된다(231조 3호 전단). 이의신청이 취하된 경우에는 처음부터 이의신청이 없었던 것으로 되므로 화해권고결정은 이의신청기간 만료시에 소급하여 확정된다.

(4) 화해권고결정에 대한 이의신청권은 그 신청 전까지 포기할 수 있다(민소 229조 1항). 화해권고결정서 또는 그 결정조서 정본이 송달되기 전에도 변론(준비)기일에서 화해권고결정 내용을 고지 받은 후에는 이의신청권을 포기할 수 있다. 당사자가 그 결정서 또는 결정조서 정본을 송달받기 전에 화해권고결정을 받아들이고자 하는 때에는 그 이의신청권을 포기함으로써 이를 조기에 확정시킬 수 있다. 이의신청권의 포기는 서면으로 하여야 하고(2항), 포기의 서면이 제출되면 상대방에게 송달하여야 한다(3항). 이의신청권의 포기는 이의신청 전까지 할 수 있으므로, 이의신청을 할 수 있는 기간인 송달 받은 날부터 2주가 도과하기 전까지 할 수 있다.

제30장

소송의 종류

마. 화해권고결정의 효력

화해권고결정에 대하여 그 결정서 또는 결정조서 정본을 송달받은 날부터 2주 이내에 이의신청이 없거나, 이의신청에 대한 각하결정이 확정된 때 또는 이의신청을 취하하거나 이의신청권을 포기한 때에는 화해권고결정이 재판상 화해와 같은 효력을 가진다(민소 231조). 여러 당사자 중 일부만이 이의신청을 한 경우에 이의신청을 하지 아니한 당사자 사이에서는 이의신청기간이 경과함으로써 화해권고결정이 확정된다. 재판상 화해는 확정판결과 동일한 효력이 있고 창설적 효력을 가지는 것이어서 화해가 이루어지면 종전의 법률관계를 바탕으로 한 권리·의무관계는 소멸함과 동시에 그 재판상 화해에 따른 새로운 법률관계가 유효하게 형성되고(대법원 2008. 2. 1. 선고 2005다42880 판결), 소송에서 다투어지고 있는 권리 또는 법률관계의 존부에 관

하여 동일한 당사자 사이의 전소에서 확정된 화해권고결정이 있는 경우 당사자는 이에 반하는 주장을 할 수 없고 법원도 이에 저촉되는 판단을 할 수 없다(대법원 2014. 4. 10. 선고 2012다29557 판결).

화해권고결정의 기판력은 그 확정시를 기준으로 하여 발생한다. 소유권에 기한 물권적 방해배제청구로서 소유권등기의 말소를 구하는 소송이나 진정명의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소송 중에 그 소송물에 대하여 화해권고결정이 확정되면 상대방은 여전히 물권적인 방해배제 의무를 지는 것이고, 화해권고결정에 창설적 효력이 있다고 하여 그 청구권의 법적 성질이 채권적 청구권으로 바뀌지 아니한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다2558 판결).

화해권고결정은 그 심급에서 판결이 선고된 때에는 효력을 잃는다(민소 232조 2항). 이 경우 결정취소 등의 절차는 필요 없다.

제5절 청구의 포기과 인낙

1. 의 의

청구의 포기는 원고가 자기의 소송상의 청구가 이유 없음을 자인하는 법원에 대한 일방적 의사표시이며, 청구의 인낙은 피고가 원고의 소송상의 청구가 이유 있음을 자인하는 법원에 대한 일방적 의사표시이다. 청구의 포기 또는 인낙이 변론조서 또는 변론준비조서에 기재되면 그 기재에 관하여 전자는 청구기각의, 후자는 청구인용의 확정판결이 있었던 것과 동일한 효력이 있게 되고(민소 220조) 소송은 당연히 종료된다.

2. 요건

가. 당사자

당사자는 소송행위의 유효요건인 당사자능력·소송능력을 갖추어야 하며, 법정대리인 또는 소송대리인에 의하는 경우에는 특별한 권한을 받아야 한다(민소 56조 2항, 90조 2항). 필수적 공동소송의 경우에는 공동소송인 전원이 일치하여 청구의 포기나 인낙을 하여야 하고(67조 1항), 독립당사자참가의 경우에는 원고나 피고가 포기하거나 인낙을 하더라도 참가인이 다투는 한 효력이 없다(79조 2항, 67조 1항).

나. 소송물

(1) 청구의 포기나 인낙의 대상은 당사자가 자유로이 처분할 수 있는 권리 또는 법률관계이어야 한다. 따라서 직권탐지주의가 적용되는 친생자관계존부확인의 소 등에서는 청구의 포기나 인낙이 허용되지 않는다. 가사소송법 12조 단서의 규정이 같은 법 2조 1항의 가류 및 나류 가사소송사건에 관하여 청구의 인낙에 관한 민사소송법의 적용을 배제하고 있는 것도 같은 이치에 기한 것이다. 주주총회결의의 흠을 다투는 소나 회사합병무효의 소 등 회사 관계 형성소송은 청구인용판결의 대세적 효력에 의하여 제3자에게 불측의 손해를 미칠 수 있고 당사자의 자유로운 처분이 허용되는 권리에 관한 것이 아니어서 청구의 인낙은 허용되지 않고(대법원 1993. 5. 27. 선고 92누 14908 판결, 대법원 2004. 9. 24. 선고 2004다28047 판결), 주주대표소송에서 청구의 포기나 인낙을 함에 있어서는 법원의 허가를 요하며(상법 403조 6항), 증권관련 집단소송에서 청구의 포기도 법원의 허가를 요한다(증집 35조 1항).

(2) 인낙의 대상이 되는 법률효과 자체가 특정되어야 하고, 인낙에 의하여 인정되는 권리관계는 현행법상 인정되는 것이어야 하며 선량한 풍속 또는 기타 사회질서에 위반되어서는 아니 된다. 청구의 포기·인낙은 화해 등과 달리 그 소의 소송물만이 대상이 될 수 있다. 주위적·예비적 청구가 병합되어 있

는 경우에, 피고가 예비적 청구만 인낙을 할 수 없으며 인낙의 취지가 조서에 기재되어 있더라도 무효이다(대법원 1995. 7. 25. 선고 94다62017 판결).

(3) 청구의 포기·인낙은 본안의 확정판결과 동일한 효력을 가지므로, 소송요건이 구비되지 않으면 법원은 청구의 포기·인낙에도 불구하고 소를 각하하여야 한다는 견해가 통설이다.

3. 절 차

가. 시 기

판결이 확정되기까지 항소심은 물론 상고심에서도 할 수 있다. 변론종결 또는 판결선고 뒤에는 포기·인낙을 위한 변론기일지정신청을 한 뒤에 지정된 기일에서 할 수 있다. 청구의 포기·인낙은 원고의 청구를 전제로 하고 있으므로 원고가 소장을 진술한 이후에 할 수 있다.

나. 방 식

청구의 포기·인낙은 변론기일 또는 변론준비기일에 말로 진술하는 것이 원칙이다. 청구의 포기·인낙은 법원에 대한 일방적 진술이므로 상대방이 법정에 출석하지 아니하여도 무방하다. 청구의 인낙은 원고의 승낙을 요하지 않으며 원고가 거절하더라도 무효가 되지 않는다.

피고가 단순히 인낙의 취지를 기재한 준비서면만을 제출한 채 기일에 출석하지 않았다면 그 준비서면이 진술간주 되더라도 인낙의 효과가 발생하지 아니하지만(대법원 1993. 7. 13. 선고 92다23230 판결), 불출석한 당사자가 진술간주되는 서면에 청구의 포기·인낙의 의사표시를 적었고 공증사무소의 인증을 받은 때에는 그 취지대로 청구의 포기·인낙이 성립된다(민소 148조 2항).

다. 조서의 작성

청구의 포기·인낙 요건이 충족되면 법원사무관등은 조서에 그 진술을 기재하여야 한다(민소 154조 1호, 155조 2항). 그 기일의 조서에는 청구의 포기나 인낙이 있었다는 취지만을 기재하고, 민사소송법 153조에 규정된 형식적 기재사항과 청구의 포기·인낙의 취지 및 청구의 취지와 원인을 적은 청구의 포기조서[전산양식 A1692] 또는 청구의 인낙조서[전산양식 A1693]를 따로 작성하는 것이 원칙이다(민소규 31조).

포기조서 또는 인낙조서에는 먼저 형식적 기재사항을 적은 뒤, 실질적 기재사항을 적는다. 실질적 기재사항으로는 조서의 첫머리에 원고가 청구를 포기하였다는 뜻 또는 피고가 청구를 인낙하였다는 뜻의 진술을 기재하고, 다음에 청구의 표시를 한다. 청구의 표시는 화해의 경우와 같이 청구취지 및 청구원인에 의하여 기재한다.

구체적인 기재요령은 다음과 같다.

(1) 포기·인낙

“원고는 이 사건 청구를 포기하였다.”, “피고는 이 사건 청구를 인낙하였다.”라고 기재하는 것이 가장 기본적인 방법이다. 병합청구 중 일부에 대하여만 포기·인낙을 하였을 경우에는 이를 특정하여 “원고는 이 사건 청구 중 피고 ○○○에 대한 청구를 포기하였다.”, “피고는 이 사건 청구 중 2025. 3. 28. 발행의 수표 금 1,000만 원의 청구를 인낙하였다.”라는 방식으로 표시하는 것도 가능하나, 당사자의 표시 및 청구의 표시란에서 당해 포기·인낙의 대상이 된 당사자 및 청구만을 명확히 표시한 다음 위의 기본적인 방법에 따라 기재하더라도 혼동의 염려가 없는 한 무방하다. 서면에 의한 청구의 포기나 인낙을 한 경우(민소 148조 2항)에는 조서에 “피고 제출의 2025. 2. 4. 자 답변서 진술간주(청구인낙)” 등으로 기재한다.

반소가 있는 경우에는 “피고(반소원고)는 본소청구를 인낙하였다.” 또는 “피고(반소원고)는 반소청구를 포기하고 본소청구를 인낙하였다.”로 기재하면 된다.

(2) 청구의 표시

청구의 표시는 청구취지와 청구원인의 기재에 의하며, 그 기재요령은 소송상 화해의 경우와 동일하다. 병합된 청구의 일부만에 관하여 포기·인낙이 있는 경우에는 청구의 표시도 그 부분만 하여야 한다. 다만 소액사건에서는 특히 필요하다고 인정되는 경우 외에는 청구의 원인을 적지 아니한다(민소규 31조).

4. 효 과

가. 소송종료효

청구의 포기나 인낙이 있는 한도 내에서 소송은 당연히 종료된다. 이를 간과한 채 심리가 속행된 때에는 법원은 소송종료선언을 하여야 한다. 포기나 인낙을 한 당사자는 패소자로서 소송비용을 부담하는 것이 원칙이며(민소 114조 2항, 98조), 그 액수에 대하여는 따로 결정으로 재판한다(114조 1항).

포기조서나 인낙조서는 확정판결과 동일한 효력이 있으므로 당연무효 사유가 없는 한 기판력 등이 생긴다. 다만 청구의 인낙은 소송을 종료시키는 효력이 있을 뿐이고, 실체법상 채권·채무의 발생 또는 소멸의 원인이 되는 법률행위라 볼 수 없다(대법원 2022. 3. 31. 선고 2020다271919 판결).

나. 흠을 다투는 방법

청구의 포기나 인낙도 조서에 기재하기 전에 철회할 수 있는지 여부에 대하여는 자백의 철회에 준하여 상대방의 동의를 얻거나 착오를 이유로 할 때에만 철회할 수 있다는 견해와 원칙적으로 언제나 철회할 수 있다는 견해가 있다.

그러나 조서 작성 후에는 그 흠은 기판력 있는 확정판결의 하자를 다투는 방법과 마찬가지로 준재심의 소에 의하여 다투어야 한다(민소 461조). 당사자가 청구의 포기·인낙조서의 당연무효를 주장하면서 기일지정신청을 한

때에는, 법원은 기일을 열어 당연무효사유가 있는지를 심리한 다음 그 사유가 존재하지 아니하면 판결로써 소송종료선언을 하여야 한다(대법원 2000.

3. 10. 선고 99다67703 판결).

소송절차 내에서 법인 또는 법인이 아닌 사단이 당사자로서 청구의 포기·인낙을 하여 이를 조서에 적은 경우에, 법인 등의 대표자가 청구의 포기·인낙을 하는 데에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 때에는 법인 등은 준재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 준재심의 소를 제기할 수 있는데, 여기서 대표자가 그 준재심의 사유를 아는 것만으로는 부족하고 적어도 법인 등의 이익을 정당하게 보전할 권한을 가진 다른 임원 등이 그 준재심의 사유를 안 때에 비로소 준재심 제기 기간이 진행된다(대법원 2016. 10. 13. 선고 2014다12348 판결).

제30장

소
송
의
종
료

5. 사무처리 등

가. 조서정본의 송달

조서는 포기·인낙이 있는 날부터 1주 안에 그 조서의 정본을 당사자에게 송달하여야 한다(민소규 56조).

나. 불복방법, 조서의 경정

조서에 대한 불복방법과 조서의 경정 등은 소송상 화해에서 설명한 바와 같다.

다. 인지액의 환급

제1심 또는 항소심에서 청구의 포기·인낙을 한 때에는 소장에 붙인 인지액의 2분의 1에 해당하는 금액의 환급을 청구할 수 있다(인지 14조 1항 4호). 그 자세한 절차는 제6장(접수사무) 참조.

제6절 기타 사유에 의한 소송의 종료

1. 사 유

전술한 바와 같이 원·피고의 지위가 혼동된 경우 또는 소송물의 성질상 승계가 허용되지 않는 소송에서 당사자가 사망한 경우에는 소송계속 중 대립당사자 구조가 소멸되는 결과가 되어 소송이 종료하게 된다.

2. 종료 후의 조치

위와 같은 소송종료사유가 발생하여 당사자가 그 사실을 증명하는 서면(가족관계등록사항증명서, 법인등기사항증명서 등)을 제출한 때에는 법원은 이를 조사하여 그 사유가 인정되면 소송이 종료된 것으로 처리하여야 한다. 당사자가 그 사실을 증명하는 서면을 제출하지 아니하거나 제출된 서류가 불충분할 때에는 민사소송법 294조에 의한 사실조회(조사의 촉탁)를 할 수 있을 것이다. 종이기록사건의 경우 소송이 종료된 것이 명백한 때에는 기록표지 다음 장의 기일지정란에 “2025. ○. ○. 당사자 지위의 혼동으로 인하여 종료”라고 기재하고(위 사유가 발생한 날을 기재한다) 재판장의 인인(認印)을 받아둔다. 전자기록사건의 경우 공용부전지 또는 별도로 생성한 문서에 위와 같이 기재하고 재판장의 확인을 받은 후 민사종국코드에 “기타”로 입력한다.

당사자가 이러한 소송종료에 대하여 다투면서 기일지정을 신청하는 경우에는 법원은 소송종료선언을 한다.

3. 당사자가 사망하고 그 상속인의 생존 여부도 분명하지 않을 경우 사건처리 방법

민사사건에서 당사자 일방이 사망하여 그 상속인의 존재 여부가 분명하지 아니한 경우에는 민법 1053조, 가사소송법 2조 1항 2호 가목 라류 37호,

가사소송규칙 78조, 79조에 의하여 상속재산관리인을 선임하여 처리하여야 한다(재민 63-20 당사자가 사망하고 그 상속인의 생존 여부도 분명치 않을 경우의 사건처리 방법).